

從公政公約第14條第5項 論刑事上訴三審之限制*

—— 兼評最高法院相關刑事裁判及
司法院釋字第752號解釋

林慈偉**

摘要

刑事訴訟法第376條之上訴三審限制規定及可能的疑義，雖然於1995年修法時已有若干討論，惟此等疑義在兩公約具國內法效力後，透過公政公約第14條第5項刑事覆判權利規定之對應，應是個重新檢視之契機，且人權事務委員會相關解釋對此權利保障有更具體之闡釋。然而，從我國最高法院相關刑事裁判的考察中發現，該等人權基準於司法實踐上並不理想，加上司法院釋字第752號解釋亦因錯失釐清公政公約與憲法解釋間關聯性之良機，也未一併處理同條法律中同樣理由違憲的爭議，使得刑事上訴三審的此一限制於司法實務操作上痼疾未去又添新病。本文主張，應修法全面檢討刑

* 本文初稿發表於中央研究院法律學研究所主辦之「第11屆憲法解釋之理論與實務研討會」，作者感謝當時與談人廖福特教授以及主持人劉靜怡教授提供諸多深刻之意見，作者亦特別感謝林明昕教授、錢建榮法官在本文寫作過程中給予諸多寶貴建議及鼓勵。本文部分章節曾收錄於《判解研究彙編（二十一）（二十二）：李模務實法學基金會105年、106年第21、22屆法學論文徵選優勝作品集》，頁43-65、頁161-189（2018年）。於該文完稿後，2017年11月刑事訴訟法第376條業併司法院釋字第752號解釋意旨為相對應之修正，惟此並未影響本文見解，本文亦已於適當處為補充析論，特此說明。
〔責任校對：郭宇傑〕。

** 台灣廢除死刑推動聯盟法務主任；國立政治大學法學博士候選人。
穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/40511112.pdf>。



事上訴三審限制規範，於修法前，普通法院則可透過解釋等方式來釐清緩和相關爭議。

關鍵詞：公民與政治權利國際公約、兩公約施行法、人權事務委員會、一般性意見、上訴權、覆判權、公平審判、司法院釋字第752號解釋、訴訟權、刑事訴訟法第376條。

目次

- | | |
|------------------------------|--|
| 壹、前言 | 肆、公政公約第14條第5項規定之解釋及適用：以人權事務委員會相關解釋論之 |
| 貳、刑事上訴第三審之限制規定及其疑義 | 一、依法覆判權利之實質保障 |
| 一、立（修）法背景：減輕第三審法院審理案件負荷 | 二、適用之程序範圍 |
| 二、擴大上訴三審限制案件範圍之疑義：1995年之修法討論 | 三、違反公政公約第14條第5項之具體例示 |
| 三、違憲疑慮 | 四、小結 |
| 四、小結 | 伍、最高法院相關刑事裁判及司法院釋字第752號解釋之檢討：以「一審無罪、二審改判有罪」之案件為例 |
| 參、公政公約之國內法效力與公平審判 | 一、最高法院102年度台上字第4532號刑事判決 |
| 一、公約之內國法化及其效力 | 二、最高法院103年度台上字第216號刑事判決 |
| 二、法院作為公約之適用主體以及「如何」適用公約 | 三、司法院釋字第752號解釋 |
| 三、公政公約中有關公平審判之規定 | 四、綜合評釋 |
| 四、小結 | 五、小結 |
| | 陸、結論 |

壹、前言

2009年，隨著《公民與政治權利國際公約》（下稱「公政公約」）之批准以及立法院通過《公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法》（下稱「兩公約施行法」）¹，兩公約成為臺灣國內法的一部分，國際人權公約與刑事法接軌的發展趨勢及借鏡即愈形重要。按兩公約施行法第2條規定：「兩公約所揭示保障人權之規定，具有國內法律之效力。」、第3條規定：「適用兩公約規定，應參照其立法意旨及兩公約人權事務委員會之解釋。」第8條規定：「各級政府機關應依兩公約規定之內容，檢討所主管之法令及行政措施，有不符兩公約規定者，應於本法施行後二年內，完成法令之制（訂）定、修正或廢止及行政措施之改進。」即包括法院在內，各級政府機關均應遵循具有國內法律效力之兩公約²。

又公政公約第14條第5項：「經判定犯罪者，有權聲請上級法院依法覆判其有罪判決及所科刑罰。」即刑事上訴權／覆判權（right to appeal/review），乃與刑事上訴制度具高度關連性之人權保障規定³，且該等規定亦經由兩公約施行法之立法而具規範拘束效力。然而，因我國刑事訴訟第二審採行覆審制，復刑事訴訟法第376條限制輕微案件刑事上訴三審之規定⁴，而可能發生二審判決撤銷一審無罪判決改判有罪卻不得上訴三審之情形，這種情況顯然與公政公約第14條第5項規定有所違背。

1 兩公約施行法並於2009年12月10日開始生效。

2 關於公約之內國法化及其效力，詳見下文「參、一」之部分。

3 SARAH JOSEPH & MELISSA CASTAN, THE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS: CASES, MATERIALS, AND COMMENTARY 507-15 (3d ed. 2013). 本文引用中出現之粗體，除特別說明外，皆為作者所強調。

4 特別說明的是，刑事訴訟法第376條業於2017年11月16日修正，不過，因本文於前半部所處理之規範疑義、公約權利論述，乃至於後半部實務判決、大法官解釋評釋之條文標的，均係以修正前之規定為準，因此，本文以下所指刑事訴訟法第376條規定主要係2017年11月16日修正前之規定。至於修正後條文，則將以「新修正」特別標示，以便區分。

對此，一方面，除政策制定者及立法者應思考立法層面應如何作法律修正之外，另一方面，也是本文關注的重點即法院作為司法人權保障之重要機關，如何在國際人權基準下，於其個案裁判上妥適、精確解釋適用公約規定，特別是當公約規定與我國既有之刑事法規範有所衝突時，法官如何透過解釋解決此等衝突、釐清國際人權基準於國內法適用問題，亦即法官於個案中應如何運用「合乎公約之內國法解釋」以避免我國刑事規制與公約保障間之衝突⁵，此等均係我國建構人權保障規定實質內涵之重要課題。

基此，本文於說明我國刑事上訴三審限制之立（修）法背景及相關疑義後，即進入本文的重點，亦即自人權公約內國法化及公約適用觀點，剖析公政公約第14條第5項之規定及意涵，並參照人權事務委員會（Human Rights Committee）⁶作成之一般性意見（General Comments）、個人申訴決定（Decision）及審查各國報告所作成之結論性意見（Concluding Observations）等解釋材料⁷；接著在此等基礎上，檢討我國最高法院近年相關刑事裁判及2017年7月大法官就刑事訴訟法第376條第1、2款作成的司法院釋字第752號解釋，進而分析該等判決就公政公約第14條第5項之解釋適用、刑事上訴三審限制等問題，並提出建議。

貳、刑事上訴第三審之限制規定及其疑義

一、立（修）法背景：減輕第三審法院審理案件負荷

我國刑事訴訟所定程序，刑事案件原則上以三審終結，不過，

⁵ 林鈺雄，刑事訴訟法（上冊），8版，頁26（2017年）。

⁶ 就人權事務委員會較完整之論述及介紹請參見YOGESH TYAGI, THE UN HUMAN RIGHTS COMMITTEE: PRACTICE AND PROCEDURE (2011)。

⁷ 關於適用公政公約時所應參照解釋材料，詳見下文「參、二」之部分。

部分案件受案件類型的特別限制而不得上訴第三審。刑事訴訟法第376條規定：「下列各罪之案件，經第二審判決者，不得上訴於第三審法院：一、最重本刑為三年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪。二、刑法第三百二十條、第三百二十一條之竊盜罪。三、刑法第三百三十五條、第三百三十六條第二項之侵占罪。四、刑法第三百三十九條、第三百四十一條之詐欺罪。五、刑法第三百四十二條之背信罪。六、刑法第三百四十六條之恐嚇罪。七、刑法第三百四十九條第一項之贓物罪。」（粗體為作者強調），即尚有以「刑度」（第1款）及「案件」（第2款至第7款）兩大基準作為不得上訴第三審案件之種類限制⁸。

從刑事訴訟法第376條的立（修）法歷程⁹來看，舊刑事訴訟法原係限制刑法第61條¹⁰所列輕微案件上訴第三審之規定，而該規定於制度上經常被認為是為減輕第三審審理案件負荷的機制；其後，該規定經1995年再次修法，為了再度減輕第三審法院負荷之故，又擴大限制上訴第三審案件之範圍^{11、12}。

8 可比較刑事妥速審判法第8條、第9條有關上訴第三審案件類型及上訴理由之特別限制。

9 參見文末【附表】刑事訴訟法第376條之修法條文及修法理由對照。

10 刑法第61條：「犯下列各罪之一，情節輕微，顯可憫恕，認為依第五十九條規定減輕其刑仍嫌過重者，得免除其刑：一、最重本刑為三年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪。但第一百三十二條第一項、第一百四十三條、第一百四十五條、第一百八十六條、第二百七十二條第三項及第二百七十六條第一項之罪，不在此限。二、第三百二十條、第三百二十一條之竊盜罪。三、第三百三十五條、第三百三十六條第二項之侵占罪。四、第三百三十九條、第三百四十一條之詐欺罪。五、第三百四十二條之背信罪。六、第三百四十六條之恐嚇罪。七、第三百四十九條第二項之贓物罪。」

11 1995年之該次刑事訴訟法之修法背景乃「因考量案件繁多，以如此繁多之案件如均適用通常程序審判，勢必耗費法官甚多精力。導致法官無法集中心力於重大繁雜之案件……為解決上開問題……認應修改刑事訴訟法，擴大簡易判決書、第二審判決書之記載及擴大限制上訴第三審案件之範圍，以減輕各級法官負擔，俾能集中精力處理較重大繁雜之刑事案件，期發揮司法功能、維護當事人權益。又因檢察官得依職權不起訴案件之範圍，依舊例與限制上訴第三審案件之範圍相同，為期加強微罪不舉之功能，乃一併配合修正。」參見立法院公報，84卷50期，頁85（1994年）。

二、擴大上訴三審限制案件範圍之疑義：1995年之修法討論

事實上，就1995年擴大限制上訴第三審案件範圍之修法，於當時經立法院司法委員會及院會審查的過程中即已產生許多質疑聲浪。若仔細研讀當時的委員會及院會紀錄，大致可以發現以下幾個疑慮：

（一）二審法院將無限制擴權

首先是對二審法院無限擴權之疑慮。例如，有委員認為微罪不舉是針對市井小民的財產犯罪，卻不准許其上訴最高法院，是沒有道理的，且刑事訴訟法第376條牽涉的案件相當多，如果規定不得上訴於第三審法院，則高等法院的判決必須要受到信服，否則高等法院法官將無限制擴權，後果堪慮¹²。

（二）檢察官依職權不起訴範圍將因而擴大

其次，則是擔憂若擴大限制上訴第三審案件「微罪」概念，是否即等同於擴大「微罪不舉」的範圍。例如，當時立法院司法委員會審查時，亦有委員指出，限制上訴第三審案件之範圍應與所謂的「微罪」概念脫鉤，理由為微罪概念涉及檢察官職權不起訴¹³，若擴大限制上訴第三審案件之微罪概念，等於擴大「微罪不舉」的範圍，將可能危害社會治安、影響犯罪觀念¹⁴。

（三）冤錯判之可能

再者，則是從冤錯案的角度提出質疑。例如有委員認為，對民

12 實則，觀諸他國立法例，譬如德國或日本刑事訴訟法亦無以刑度或案件罪名作為限制三審上訴之此般特殊規定。

13 立法院公報，83卷51期，頁138-139（1994年）。

14 刑事訴訟法第253條：「第三百七十六條第一項各款所規定之案件，檢察官參酌刑法第五十七條所列事項，認為以不起訴為適當者，得為不起訴之處分。」

15 立法院公報，83卷51期，頁133-134（1994年）。

眾而言，不管是判6個月或1年，都會覺得是不應該的、是冤枉的，不能以法院業務繁忙，就認為輕罪不用上訴¹⁶。又如，有委員認為，法官是人不是神，疏失之處在所難免，其本身即接獲不少陳情，有些案件第一審判決無罪，第二審卻改判有罪，如果不得上訴第三審法院，類似情況中的法官權限是否過度擴大，此等均應予以考量¹⁷。亦有認為，擴大不得上訴三審法院之範圍可能造成「冤情」救濟程序的不完備，至人民權益於不顧，不可不慎¹⁸。

（四）審級利益之剝奪

另亦有委員從審級利益之角度認為，是否可以為了減輕法院的負擔，在我國法院司法審判品質不高之際，剝奪很多案件當事人上訴第三審的權益、減少當事人的審級利益，此等均應特別考量¹⁹。

從上開疑慮所持論點及理由可以發現，除了剝奪審級利益之觀點外，委員們提出的各該質疑有個共通點，就是對司法或公權力的不信賴。例如，擔憂二審法院成為部分案件的終審法院後，造成法院微罪不舉的適用案件範圍擴大、因法官疏失造成冤錯案、審判品質不高等等。不過，這些質疑，基本上都較偏向消極面的論述，而非積極性地面對「上訴三審限制案件範圍」規定本身的正當性及立論基礎等問題。

又雖於1995年修法過程中，有為數不少的委員提出上開疑慮及擔憂，然而，該擴大上訴三審限制案件範圍規定，仍於1995年10月5日三讀通過。

16 立法院公報，83卷53期，頁5（1994年）。

17 立法院公報，83卷51期，頁139（1994年）。

18 立法院公報，83卷51期，頁141（1994年）。

19 立法院公報，83卷51期，頁143（1994年）。

三、違憲疑慮

和上開從消極面向所提出的質疑不同的是，學界就刑事訴訟法第376條上訴案件限制規定以及1995年擴大適用範圍之修法，大多從憲法及刑事訴訟論理直接對規定本身提出檢討及批評。

例如，林山田教授認為，刑事案件有無必要上訴第三審法院，關鍵乃在於有無法律爭論點，而非案件輕重，況且，存有法律問題爭論之案件，並不限於重大案件，即使是輕微案件，也有可能刑事事實體法上存在須待最高法院表示法律意見，並用以統一法律見解之情況，而透過該規定剝奪特定被告之第三審上訴權，實屬違憲之舉，其更進一步認為，刑事訴訟法1995年修正時，一味只想減輕最高法院之負擔，而未考慮人民之平等權與訴訟權，反而擴大了不得上訴第三審之罪名，犧牲被告之訴訟權以減輕法官之負擔，如此修法，更擴大了違憲之範圍，顯屬不當²⁰。對此，柯耀程教授則認為，刑事訴訟法第376條限制上訴三審規定非如林山田教授所直指為違憲，理由是，並非所有案件不論輕重難易均應許以完結所有程序，方屬程序正當，在程序事項不侵犯基本權的前提下，自得以種種考量為限制審級救濟²¹。

又如，陳運財教授則自「統一解釋法令」及刑事第三審目的等觀點認為，刑事訴訟法第376條以減輕第三審法院負荷為由即限制輕微案件上訴第三審之權利，理由並不相當²²：

20 林山田，刑事程序法，5版，頁702-703（2004年）。林鈺雄教授亦從憲法訴訟權、比例原則、平等原則等角度同樣提出違憲疑慮觀點，參見林鈺雄，刑事訴訟法（下冊），8版，頁445（2017年）。

21 柯耀程，限制三審上訴之規範檢討——評釋字第七五二號解釋，月旦法學雜誌，271期，頁150-151（2017年）。

22 陳運財，我國刑事訴訟上訴審構造之檢討，收於：最高法院學術研究會編，「刑事訴訟起訴狀一本主義及配套制度」法條化研究報告（下），頁509（2001年）。

第三審上訴採行法律審之目的既然在於審查原審判決有無違法、有無影響事實的認定，以統一法令之解釋，則理論上，不論案件之種類或輕重，倘原審判決違背法令，而有由第三審法院予以審查糾正，以收統一法令解釋目的之必要者，均應容許其提起第三審上訴，始為合理……當我們警覺第二審覆審的結果，仍充斥著應調查證據未予調查或是判決理由矛盾之判決違背法令的情況時，我們怎能令這麼多的刑事案件無從接受事後審查，而求救無門呢！

惟有文獻仍認，刑事訴訟法第376條所列各罪之案件，或係案件輕微，或因利害較淺，且絕大多數涉及財產法益之罪，為求迅速終結故不許其於判決後再上訴於第三審²³。

或有認為，按我國大法官對於上訴救濟制度之數號解釋意旨²⁴，所謂上訴救濟係屬立法者之自由形成，未必要有三級三審之救濟²⁵。惟就訴訟權之保障以及刑事訴訟法第376條限制輕微案件上訴權利之正當性，尚不能僅以審級制度不屬訴訟權核心內容，全然委諸立法裁量一詞帶過，誠如許宗力大法官於司法院釋字第574號解釋協同意見書中所言²⁶：

23 林永謀，刑事訴訟法釋論（下冊），改訂版，頁92（2010年）。

24 例如司法院釋字第396、442、512等號解釋。

25 吳燦，最高法院刑事案件之言詞辯論——兼論不得上訴第三審案件的救濟，法官協會雜誌，18卷，頁100-101（2016年）；朱石炎，刑事訴訟法論，修訂3版，頁4571（2011年）。

26 許宗力大法官於協同意見書中更進一步指出「或有主張只要法院審判程序符合正當法律程序要求，即便功能在處罰人民，且是一級一審，不提供進一步救濟機會，對人民權利也已提供足夠保障，故審級制度屬立法裁量的命題仍可以維持。惟這種看法還是未能走出『司法功能純粹在於人民權利之救濟與保障，而不在人民權利之限制』的迷思。依本席之見，無論如何，只要判決本身對人民而言是構成公權力對其權利的初次侵害，無論其遵循程序是如何符合法治國訴訟正當程序的要求，就改變不了其行為本質不在救濟，而在限制或侵犯人民權利之事實。而只要本質在人民權利之限制，就不能沒有司法之救濟。」參見司法院釋字第574號解釋許宗力大法官協同意見書。

惟在某些領域，如果法院的裁判，其功能不是在於救濟，而是在處罰人民，例如本院公務員懲戒委員會議決的懲戒處分，或普通法院刑事庭的第一審有罪判決，則其情事事實上與行政權作成限制人民權利之行政處分沒有兩樣，都構成公權力對人民的初次權利侵害……此時受侵害之人民自有根據憲法保障之訴訟權請求另一審級法院救濟之權利

亦即其認為不讓人民有請求另一審級法院審查該處罰人民之法院的判決（或議決）以謀求救濟之機會，即與權利救濟之拒絕無異，而有牴觸訴訟權保障之虞，尚不能以審級制度不屬訴訟權核心內容而委諸立法裁量為由，脫免違憲指摘。

甚者，更有文獻從權力分立角度指出，大法官歷來所謂「審級救濟屬立法者裁量範圍」此一意見，除欠缺憲法、國際人權法學理依據之外，亦未意識到審級救濟制度同時也是權力分立議題，蓋審級救濟制度不單純只是人民訴訟權保障而已，其更可能是司法與立法二權衝突之議題，因而無法純粹以立法裁量角度為立論²⁷。

不過，直至2017年7月，大法官終於對刑事訴訟法第376條中的第1款及第2款作出司法院釋字第752號解釋，認為刑事訴訟法第376條第1款及第2款規定：（1）就經第一審判決有罪，而第二審駁回上訴或撤銷原審判決並自為有罪判決者，規定不得上訴於第三審法院部分，屬立法形成範圍，與憲法第16條保障人民訴訟權之意旨尚無違背；（2）就刑事第二審撤銷原審無罪判決並自為有罪判決者，被告不得上訴於第三審法院部分，未能提供至少一次上訴救濟之機會，與憲法第16條保障人民訴訟權之意旨有違，應自司法院釋字第752號解釋公布之日（2017年7月28日）起失其效力。就該號解釋及其後續效應，本文將於「伍、四、（四）」處提出相關分析評釋。

²⁷ 林超駿，論合憲審級救濟之建構——以大法官立法裁量見解為中心，憲政時代，38卷3期，頁391（2013年）。

四、小結

雖然在1995年擴大限制上訴第三審案件範圍之修法過程中，從立法院司法委員會及院會審查紀錄就可看出諸多對於上訴三審限制案件範圍規定的質疑聲浪，不過，當時基本上仍以司法不信賴等消極面的考量點居多，而非從積極面上自訴訟當事人本身的訴訟權益、救濟可能等角度來探討該規定之合理性。

就上開觀點，本文初步認為，於憲法層面上，或有平等原則（等者等之、不等者不等之），抑或是訴訟權等討論，惟基於司法資源有限性以及審級制度設計之於訴訟權利，亦非要求國家對於刑事案件應設立無限上綱、永無止境的審級及審理機會²⁸，就輕重罪給予不同程度之審級救濟，且其間存有合理的差別待遇，在兼顧司法資源的合理有效運用的利益考量下，亦應符比例原則，似難逕以認定該規範係屬違憲²⁹。

不過，某規定之「不違憲」，並不代表其於刑事立法或政策面向上即為適當、合理³⁰。

於刑事立法及政策層面上，就刑事訴訟法第376條規定，本文認為，首先，不論是舊刑事訴訟法原係限制刑法第61條所列輕微案件之第三審上訴之立法原意，或1995年之修法背景，均是認為欲藉此等規定達到減輕第三審審理案件負荷之目的，但按刑法第61條之立法目的，係為避免有法重情輕之個案，而列舉得免除其刑之情形，此與刑事訴訟法第376條之「減輕第三審審理案件負荷」之立法目的迥然有別，故二者間不必然須為相同之規範；其次，刑事訴

²⁸ 陳運財（註22），頁514。

²⁹ 不過，如前揭所述，於規範上自始不讓人民有請求另一審級法院審查該處罰人民之法院的判決以謀求救濟之機會，連一次救濟機會均無之情況者，此即與權利救濟之拒絕無異，有憲法訴訟權違反之問題。

³⁰ 譬如司法院釋字第554號解釋認為刑法通姦罪未違反比例原則而作出合憲解釋，然此並不代表通姦罪之存在於刑事立法上或刑事政策上即為合適。

訟法第376條第2款以下所列之刑法竊盜罪、侵占罪、詐欺罪、背信罪、恐嚇罪及贓物罪等，該等罪名之最重本刑均為5年以下有期徒刑，亦非原所設想之「輕罪」範圍，實不應任意剝奪被告上訴第三審之機會；再者，從刑事上訴三審之目而言，本文亦贊同上開陳運財教授所持觀點亦即刑事訴訟法第376條以減輕第三審法院負荷為由即限制輕微案件上訴第三審之權利，其理由並不相當；最後，應當思考的是，限制甚至擴大上訴第三審之範圍，乍看之下似可疏減最高法院部分訟源、減輕法官負荷，但在未一併考量如何加強事實審功能、釐清刑事案件類型負擔來源、推動改善司法環境乃至於增加員額以減輕法官工作量之前提下，此充其量不過是一種鋸箭式的作法，且此種鋸箭式的作法所付出的代價，除了犧牲人民之訴訟權益之外，冤判的空間也隨之增加。

然而，即便在1995年修法之後也陸續有論者明確指出上開訴訟權侵害、違反平等權、不符刑事第三審目的等疑慮之情形下，直至司法院釋字第752號解釋出爐前，立法者於過去這段時間似乎也沒有任何修法的進展或改善作為。不過，隨著兩公約的批准及兩公約施行法之施行，在國際人權公約架構底下，以與內國刑事程序關聯高度密切的公政公約對應於國內既有的刑事規制，進而就刑事訴訟法第376條規定及上揭疑慮做重新檢視，似乎是個可能的契機。

參、公政公約之國內法效力與公平審判

一、公約之內國法化及其效力

近年來，我國致力於聯合國各人權公約內國法化之推動³¹。不

31 除兩公約（《公民與政治權利國際公約》、《經濟社會文化權利國際公約》）之外，我國近幾年來就《消除對婦女一切形式歧視公約》、《兒童權利公約》、《身心障礙者權利公約》亦均以「施行法」之方式，一一將該等公約國內法化。

過，各人權公約縱使被視為國內法規範，但其性質及位階為何，仍應先予以討論。

在關於各個國際人權公約對於我國內國法制究竟有無規範效力此一脈絡中，首應面對的問題是，相關公約之批准（*ratification*）是否因而成為國內有效法規範。關此，公約作為國際法上之條約，是否具國內法效力，學說上向來有一元論、二元論等爭論；而就國家批准條約行為的作用性質，亦有轉型說（*theory of transformation*）及併入說（*theory of incorporation*）等觀點³²。又因我國目前的國際地位以及現實情況等因素，聯合國秘書處亦不可能接受我國為存放目的而送交之公約批准書的事實，譬如臺灣政府曾於2009年6月8日將兩公約批准書送至聯合國秘書長處存放（*deposit*），惟於同年月15日聯合國隨即回函表示依聯合國2758號決議文「承認中華人民共和國代表為中國在聯合國內之唯一合法代表」，因此無立場接受存放我國兩公約的批准書。基此，至少從兩公約上開經驗，囿於現實情況，相關之人權公約規範，似難以從上開國際法學理論基礎推論出該等人權公約對我國係具有條約拘束力等說法。不過有文獻認為，從國際條約法中國家片面對條約表示願意遵守之意思表示亦能使該條約對國家產生拘束力且負有實踐國家義務觀之，此項疑慮應可被化解³³。

就人權公約對於我國之拘束力，目前至少可以確定的是，就兩公約之部分，2009年通過之兩公約施行法規定使兩公約成為我國國內有效法律之事實。因為從兩公約施行法第2條：「兩公約所揭示保障人權之規定，具有國內法律之效力。」即可得知，兩公約之落實及其拘束力已因兩公約施行法之規定而成為國內法律。

32 徐揮彥，「公民與政治權利國際公約」與「經濟、社會與文化權利國際公約」在我國最高法院與最高行政法院適用之研究，*臺大法學論叢*，43卷特刊，頁845-846（2014年）。

33 徐揮彥（註32），頁894。

不過，就立法院以法律案三讀通過「兩公約施行法」之方式，有文獻特別說明此乃為避免我國無法交存批准書於聯合國秘書處而對兩公約效力產生質疑所設的「雙重保險」，亦即制定兩公約施行法只是再度「確認」上述效力，並且進一步就兩公約規範之實施及規範位階與國際審查程序為特別規定，因此不應將兩公約中人權保障規範之效力權源視為僅來自於兩公約施行法³⁴。

亦有文獻從國際人權法實踐及發展脈絡認為，兩公約施行法明白揭示兩公約在正式施行後具有國內法律位階，因為綜觀目前國際法社群對於強行國際法內涵的共識以及人權事務委員會的觀點，兩公約的部分權利內容，已構成強行國際法或絕對法，而於國內法律體系的位階應等同於憲法，縱使兩公約施行法對兩公約所保障之權利僅賦予國內法律之效力，但在我國法律體系下的任何規範，均不得牴觸這些具有絕對法性質的人權規範，再根據國際人權法上目前多數的實踐、判例及學說，兩公約所保障的人權規定，已具備習慣國際法之地位，在我國內國法律體系內應可直接適用，無待正式批准兩公約或制定兩公約施行法，是我國對兩公約的批准或兩公約施行法的正式實施，僅是對此一立場的再次確認，甚而，從跨國憲政主義的發展脈絡，也可以看到兩公約在各國的內國法律體系下的規範位階有明顯提高的現象³⁵。

在確定兩公約國內法律效力之後，從上開討論應可看出一個更為棘手的問題是，兩公約之法位階疑義。蓋兩公約施行法第2條僅揭示「兩公約具國內法效力」，也就是說，其對於公約之國內法位階為何並未明確規定，但位階問題實將牽涉法院於具體個案中應否適用公約的判斷，因此，茲就公約之位階問題繼續討論如下。

34 徐揮彥（註32），頁851。

35 張文貞，國際人權法與內國憲法的匯流：台灣施行兩大人權公約之後，收於：台灣法學會編，台灣法學新課題（八），頁1-26（2010年）

就公約之法位階問題，國內學說有認為公約屬「高於法律、低於憲法」之位階³⁶，另有認為兩公約權利規範優於國內法之意見³⁷。於兩公約施行之前，法務部法規委員會（現法務部法制司）就此亦曾有做過研究並認為國內法令與兩公約規定牴觸時，兩公約規定應優先適用，理由是兩公約乃普世遵循之人權規範，故兩公約之內容具有人權保障意義上之正義性、普遍性及不可剝奪性³⁸。

惟有文獻認為，我國對於兩公約並非以條約案之方式來轉化引進兩公約，而是以法律案之制定程序來使其在國內生效，因此有關兩公約之性質，應已轉化國內法性質，成為國內法之一部分，而非屬國際條約性質，其位階應與國內法律相同，並未優於國內法律或具憲法位階之效力，又當兩公約或其施行法與國內法有所衝突時，應適用後法優於前法原則，即立法院有意以後面所制定之法律來取代先前所制定之法律的意思，優先適用兩公約與其施行法³⁹。不過，對此，有文獻持反對意見，認為按「後法優於前法」之論理，公約之權利規範將會被多數龐大之國內法所取代，其實質結果是根

36 林鈺雄（註5），頁26；林佳範，論兩公約對憲法人權保障的補充——一個初步架構的探討，全國律師，14卷3期，頁25（2010年）。

37 廖福特，聯合國與人權保障——監督機制、條約內涵、台灣實踐，頁186（2013年）；鄧衍森，人權保障的規範理論：序曲，台灣法學雜誌，166期，頁126-127（2010年）；徐揮彥（註32），頁857；彭坤業，落實兩公約人權新紀元，全國律師，14卷3期，頁11（2010年）。

38 法務部對《「國際公約內國法化的實踐」委託研究報告》之對案建議，法務部，<https://www.humanrights.moj.gov.tw/media/20210593/%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8%E5%B0%8D-%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E5%85%AC%E7%B4%84%E5%85%A7%E5%9C%8B%E6%B3%95%E5%8C%96%E7%9A%84%E5%AF%A6%E8%B8%90-%E5%A7%94%E8%A8%97%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%A0%B1%E5%91%8A-%E4%B9%8B%E5%B0%8D%E6%A1%88%E5%BB%BA%E8%AD%B0-%E8%A1%8C%E6%94%BF%E9%99%A2%E7%A7%98%E6%9B%B8%E9%95%B799%E5%B9%B43%E6%9C%8829%E6%97%A5%E9%99%A2%E8%87%BA%E6%B3%95%E5%AD%97%E7%AC%AC0990006602%E8%99%9F%E5%87%BD.pdf?mediaDL=true>（最後瀏覽日：2021年11月1日）。

39 黃明展，論兩公約施行法之生效對判決與執行死刑之影響（上），司法周刊，1492期，頁2-3（2010年）。

本不會適用公約之權利規範，此除將架空公約外，亦不符合批准公約使之有國內法地位之原始宗旨，因此，主張「後法優於前法」之說法不可採，此外，其更進而認為，於此情況下，應有兩方向可循：第一，認定公約是特別法，應優先適用之；第二，以法律衝突論，亦即當國內法與公約權利保障衝突時，不適用之⁴⁰，況且兩公約施行法第2條雖規定：「兩公約所揭示保障人權之規定，具有國內法律之效力。」但並沒有明白表示兩公約「只有」一般國內法地位⁴¹。

值得一提的是，就公約之位階問題，國際獨立專家早於2013年3月的「對中華民國（臺灣）政府落實國際人權公約初次報告之審查國際獨立專家通過的結論性意見與建議」第14段中即已指出「專家發現，因兩人權公約施行法之效果，使兩人權公約之條款成為中華民國（臺灣）法律的一部分，且位階高於與之牴觸的法律，唯低於《憲法》。然而，專家觀察到司法判決極少引用兩人權公約。⁴²」據此，兩公約作為本國法之適用，並無疑議，甚至應高於一般刑事法規之位階⁴³。

40 廖福特，法院應否及如何適用公民與政治權利國際公約，台灣法學雜誌，163期，頁52（2010年）。

41 廖福特，司法審判於兩公約人權保障思維所面臨之挑戰——行政法院適用兩公約之檢視，法學叢刊，59卷2期，頁33（2014年）。

42 原文為：“14. The Experts note that, as a result of the Implementation Act, the provisions of the two Covenants are part of Taiwanese law and prevail over inconsistent domestic laws other than the Constitution. They observe, however, that the Covenants continue to be invoked only rarely in judicial decision-making.” 參見對中華民國（臺灣）政府落實國際人權公約初次報告之審查國際獨立專家通過的結論性意見與建議，法務部，<https://www.humanrights.moj.gov.tw/media/12490/312259531585.pdf?mediaDL=true>（最後瀏覽日：2021年11月1日）。

43 王正嘉，論死刑之裁量與界限：以兩公約與比較法為出發，臺大法學論叢，45卷2期，頁693（2016年）。

二、法院作為公約之適用主體以及「如何」適用公約

如前所述，兩公約及其施行法自2009年12月10日開始施行。又按兩公約施行法第2條及第8條規定，兩公約具有國內法之效力。惟對於法院而言，應先探討者乃法院是否應適用公政公約，也就是我國法院是否受公約拘束，對此，可作以下之理解及分析。

首先可先自兩公約施行法第4條作文義觀察，按兩公約施行法第4條規定：「各級政府機關行使其職權，應符合兩公約有關人權保障之規定，避免侵害人權，保護人民不受他人侵害，並應積極促進各項人權之實現。」其中所謂「各級政府機關」並未特別排除司法部門，或將之限縮於「行政機關」，足認法院亦應涵蓋在內。而就法院是否屬兩公約施行法第4條之「各級政府機關」之範疇，先前之討論如法務部人權工作小組於第6次會議（2014年4月21日）⁴⁴中，高榮志委員提案說明：「目前民間就兩公約施行法有提出修法版本，修正條文計有施行法第2條應優先適用兩公約、第3條適用兩公約應依立法意旨、公約序言、兩人權公約事務委員會之解釋、部分條文所稱『各級政府機關』應包含法院，及第8條法令及行政措施之檢討不限於2年等修法建議，可否請法務部研議修正施行法之可行性，以回應民間之意見」，雖當時會議決議為「高委員所提現行施行法之疑義，本部已採相關作為或採相關解釋方法因應，而未有重大窒礙難行之處，且目前各界也有共識，本案請法制司未來如需修正施行法時，列入參酌。」然此仍顯示出法令規範的嚴密性係屬重要，不可不慎。

對此，有文獻自國內法體系及比較法觀點指出，我國其他國內法亦有「各級政府機關」之字眼⁴⁵，但這些法律也並無限縮於行政

44 法務部人權工作小組第6次會議紀錄，法務部，<https://www.humanrights.moj.gov.tw/media/13478/45710425390.pdf?mediaDL=true>（最後瀏覽日：2021年11月1日）。

45 例如：二二八事件處理及賠償條例第10條、土地法第26條、公益勸募條例第5條第2項、公務人員協會法第2條等規定。

體系而已，亦包括司法部門，且按我國兩公約施行法缺乏更進一步明確規範法院受兩公約拘束之規定，且就比較法觀點而言，若制定特別立法使國際人權條約具國內法地位，但卻推論國內法院不應適用該國際人權條約，此實殊難想像，且亦將實質上導致棄毀國際人權條約的國內法時效性⁴⁶。

另外一個法院具適用公約義務的可能觀點是，即便認為兩公約施行法第4條之「各級政府機關」此文義無法涵蓋法院，但於此情形下，既然公約之人權規定已經由兩公約施行法之規定而成為「法律」，那麼法官亦應按我國憲法第80條之規定：「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」即基於「依據法律」此一明文誠命而具適用公約之義務。

事實上，若從法院過去適用公約之經驗觀之，自兩公約施行迄今，以公政公約為例，已有不少之適用經驗。以最高法院裁判適用公政公約為例，若以關鍵字（公約、公民與政治權利國際公約、公政公約等字詞）搜尋司法院法學資料檢索系統可發現，我國最高法院自2009年12月10日兩公約施行起至2017年5月25日止，適用公政公約之裁判至少即有159則。

於確定法院係公約之適用主體後，接著應就公約適用之內容即兩公約施行法第3條規定之部分為說明。

按兩公約施行法第3條規定：「適用兩公約規定，應參照其立法意旨及兩公約人權事務委員會之解釋。」可知，解釋我國法應參考兩公約人權規定、立法意旨以及人權事務委員會之相關解釋。就此，應先釐清以下三個問題。

46 廖福特（註37），頁169。

第一，關於兩公約施行法第3條中稱「兩公約人權事務委員會」，兩公約施行法第3條未將與「人權事務委員會」(Human Rights Committee)同為司職兩公約監督之「經濟社會及文化權利委員會」(Committee on Economic, Social and Culture Rights)一併列入，此實為我國立法上之疏漏⁴⁷，因此，「兩公約人權事務委員會」所指意義，在此應理解為，就公政公約，是指「人權事務委員會」，就經濟社會文化權利國際公約（下稱「經社文公約」），則是指「經濟社會及文化權利委員會」。

第二，兩公約人權事務委員會之「解釋」。對此，若是在公政公約的脈絡下，兩公約施行法第3條規定要求應參照人權事務委員會之解釋，此規範要求法院不僅僅是應適用條約之文字而已，亦必須參照人權事務委員會之解釋內容以及該內容所形成之法律內涵。

基此，關於公政公約最為基本以及最為權威的解釋便是人權事務委員會所作的一般性意見。除此之外，因為就公政公約締約國之義務有三種類型：包括國家報告（state report）、國家訴訟（inter-state communication）、個人訴訟（individual communication）。不過，人權事務委員會至今從來沒有審理過任何國家訴訟案件，因而實質上只有從審查國家報告及個人訴訟而解釋公約，而人權事務委員會亦會將其審查國家報告及個人訴訟之意見彙整成一般性意見。因此，除了一般性意見之外，人權事務委員會就各國報告之結論性意見（Concluding Observations）以及個人申訴所作的決定（Decision），也都是人權事務委員會解釋的一部分，是以，此等解釋中所呈現的法律內涵及原則均係解釋公政公約之重要參考內容及材料⁴⁸。

47 張文貞，演進中的法：一般性意見作為國際人權公約的權威解釋，台灣人權學刊，1卷2期，頁40-41（2012年）。

48 有文獻表示，聯合國經濟及社會理事會所通過之準則，與人權委員會通過的決議，均有類似國際法之特質且均為軟法，因而於裁判中不需要再引用，或是僅作為論述之輔助，如果我國法院要「適用」的話，應該透過習慣國際法之

具體而言，截至目前為止，於我國最高法院裁判中，就公約相關解釋及材料之參照此一層面，最為重要且經典之案例莫過於2015年定讞⁴⁹之「陳昆明殺人案」。該案於第一次上訴最高法院時，最高法院曾於102年度台上字第4289號刑事判決中表示：「其中我國於98年5月14日簽署『公民與政治權利國際公約』及『經濟社會文化權利國際公約』（合稱兩公約），立法院隨即制定兩公約施行法，並於同年12月10日施行。上開施行法第2條規定，兩公約所揭示保障人權之規定，具有國內法之效力。第3條規定，適用兩公約規定，應參照其立法意旨及兩公約人權事務委員會之解釋。而公民與政治權利國際公約第6條第1項明定：『人人皆有天賦之生存權。此種權利應受法律保障。任何人之生命不得無理剝奪。』第2項亦規定：『凡未廢除死刑之國家，非犯情節最重大之罪，且依照犯罪時有效並與本公約規定及防止及懲治殘害人群罪公約不牴觸之法律，不得科處死刑。』。另依西元1984年5月25日聯合國經濟及社會理事會決議批准公布之『保障死刑犯人權保證條款』第3條，明確規範對於精神障礙者不得執行死刑；再聯合國人權事務委員會復於西元2005年之2005/59決議第7項，進而要求所有仍維持死刑之締約國，不得對任何精神或智能障礙者判處或執行死刑（原文為：《The resolution》Urges all States that still maintain the death penalty... (c) Not to impose the death penalty on a person suffering from any mental or intellectual disabilities or to execute any such person）。嗣於西元2013年對中華民國（台灣）政府落實國際人權公約初次報告之審查國際獨立專家通過的結論性意見與建議第57項，仍要求我國直到完全廢除死刑之前，應嚴格遵守相關程序及實質之保護措施，特別是心理或智能障礙者不得被判處死刑或執行死刑。均已明確宣示我國刑法雖得科處死刑，然人之生存權，應受法律保障，死刑之剝奪生

途徑。參見廖福特，最高法院的公民與政治權利國際公約難題／最高院103台上3062判決，台灣法學雜誌，257期，頁195（2014年）。

49 最高法院104年度台上字第717號刑事判決。

命，具有不可回復性……」即以兩公約施行法、公政公約及其相關解釋為立論基礎揭示「精障者不得判處死刑」此一國際人權基準。

第三，就兩公約施行法第3條所提到的參照「立法意旨」之部分，按現行司法實務，實仍未見有任何裁判對此表示意見。就此，有文獻認為，兩公約施行法第3條所謂立法意旨難以確認，不過，此應可由兩公約共同之前言得知，蓋依兩公約共同之前言，其中強調人性尊嚴理念，同時也呼籲實踐聯合國憲章之人權條款及世界人權宣言，這些概念都可以作為我國實踐兩公約施行法第3條之基礎⁵⁰。

對此，本文認為，所謂參照立法意旨，應該包含公約的內涵、準備前言、文件等等這些內容，亦即就立法意旨之探詢，至少應該是指兩公約的前言，其中，詮釋所謂的立法意旨時，若能再配合條約的發展、歷史背景、準備材料（travaux préparatoires），乃至於維也納條約法公約（The Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969）第31條：「1. 條約應依其用語按其上下文並參照條約之目的及宗旨所具有之通常意義，善意解釋之。2. 就解釋條約而言，上下文除指連同序言及附件在內之約文外，並應包括：2.1. 全體當事國間因締結條約所訂與條約有關之任何協定；2.2. 一個以上當事國因締結條約所訂並經其他當事國接受為條約有關文書之任何文書。3. 應與上下文一併考慮者尚有：3.1. 當事國嗣後所訂關於條約之解釋或其規定之適用之任何協定；3.2. 嗣後在條約適用方面確定各當事國對條約解釋之協定之任何慣例。3.3. 適用於當事國間關係之任何有關國際法規則。4. 倘經確定當事國有此原意，條約用語應使其具有特殊意義。⁵¹」以及第32條：「1. 為證實由適用第31條所得之

50 廖福特（註41），頁6；廖福特，「公民與政治權利國際公約」國內法化之影響：最高法院死刑相關判決之檢視，臺大法學論叢，43卷特刊，頁916（2014年）。

51 原文為：“General rule of interpretation

1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object

意義起見，或遇依第31條作解釋而：1.1. 意義仍屬不明或難解；或1.2. 所獲結果顯屬荒謬或不合理時，為確定其意義起見，得使用解釋之補充資料，包括條約之準備工作及締約之情況在內。」等規定⁵²所揭示之解釋原則，如此可能會較容易、全面性地釐清公約規範之解釋及其內涵⁵³。

至於法院應「如何」(how)將公約適用於具體個案之問題，也就是說，既已肯認法院於裁判時應適用公約，但於具體個案中，法院究應如何或遵循什麼步驟以便其於具體個案中適用公約，此誠值探究。

and purpose.

2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, including its preamble and annexes: (a) any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connection with the conclusion of the treaty; (b) any instrument which was made by one or more parties in connection with the conclusion of the treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the treaty.
3. There shall be taken into account, together with the context: (a) any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of its provisions; (b) any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation; (c) any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties.
4. A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended.”

52 原文為：“Supplementary means of interpretation

Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the application of article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to article 31:

(a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or

(b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable.”

53 事實上，就公約之解釋問題，人權事務委員會也曾於*Alberta Union v. Canada* (118/1982)一案中就公約條款解釋之問題明確表示意見。其認為，公約之解釋應當依循維也納條約法公約中所規定之一般性解釋規則 (General rule of interpretation)。See Human Rights Committee, *J. B. et al. v. Canada*, Communication No. 118/1982, U.N. Doc. Supp. No. 40 (A/41/40) at 151 (1986), para. 6.3.

對此，有認為我國法院應參照前揭維也納條約法公約規定對公約進行解釋及適用，而步驟上則應依維也納條約法公約第31、32條進行，分別為文義解釋、體系解釋、目的解釋及補充解釋等程序方法，此外，並應依兩公約施行法第3條規定，參照人權事務委員會的評議及決定來作解釋⁵⁴。

有文獻更從兩公約施行法第3條規定建議法院可依循以下具體的適用步驟：「1、確認本案事實是否與（公民與政治權利國際）公約所保障之權利有關；2、如果有的話，與哪些權利有關；3、人權事務委員會對這些權利的詮釋內容為何；4、國內法律規範是否與這些權利內容衝突；5、決定依據國內法律或是公約為判決。並於論證過程中參照人權事務委員會審查各國報告之意見、個案申訴之決定、一般評論意見。⁵⁵」

另有文獻認為，在國際人權公約內國法化的觀點下，據兩公約施行法第2、3條規範可知，解釋我國法應參考兩公約人權規定、立法意旨及相關解釋，而關於公政公約最為基本以及最為權威的解釋，便是人權事務委員會作成的一般性意見，除此之外，其更進一步指出，因二次戰後國際人權法的發展具有相互參照之特性，國際人權機構相互援引見解，甚至於作為實質法源，乃是常態，又加上公政公約制定時曾參考當時已生效的歐洲人權公約之體例和內容，而人權事務委員會陸續作成的一般性意見，亦時有援用歐洲人權法院案例法之情形，因此歐洲人權法院所作的相關裁判亦值參照⁵⁶。

以上就公約之內國法化、公約效力及位階，乃至於法院應「如何」適用公約等偏向公約適用「總論性」之析論後，緊接著將進入

54 廖宗聖，公民與政治權利國際公約在我國的效力——以最高及高等法院刑事裁判為研究中心，中華國際法與超國界法評論，7卷1期，頁125（2011年）。

55 廖福特（註37），頁191。

56 林鈺雄，2012年刑事程序法發展回顧：從國際人權公約內國法化的觀點出發，臺大法學論叢，42卷特刊，頁1070（2013年）。

本文所關注之重點議題即公約適用「各論性」的探討：刑事上訴三審限制與公政公約的公平審判規制。因此，以下即就公政公約中有關公平審判條款之規範結構作說明。

三、公政公約中有關公平審判之規定

在公政公約中，與我國刑事訴訟關聯最直接、重要規定者，除公政公約第7條酷刑禁止之外，就是第14條的公平審判規定⁵⁷。又與本文所欲探討之刑事上訴三審限制此一審級救濟議題相關者——公政公約第14條第5項覆判權利規定——即屬此公平審判架構下的一環。既本文係以公政公約規定作為探討之切入點，則在進入公政公約第14條第5項規定之解釋適用前，實有必要先就公政公約脈絡中有關公平審判之規範結構為介紹及說明，以便釐清本文所探討議題之落點所在。

57 公政公約第14條：「一、人人在法院或法庭之前，悉屬平等。任何人受刑事控告或因其權利義務涉訟須予判定時，應有權受獨立無私之法定管轄法庭公正公開審問。法院得因民主社會之風化、公共秩序或國家安全關係，或於保護當事人私生活有此必要時，或因情形特殊公開審判勢必影響司法而在其認為絕對必要之限度內，禁止新聞界及公眾旁聽審判程序之全部或一部；但除保護少年有此必要，或事關婚姻爭執或子女監護問題外，刑事民事之判決應一律公開宣示。二、受刑事控告之人，未經依法確定有罪以前，應假定其無罪。三、審判被控刑事罪時，被告一律有權平等享受下列最低限度之保障：（一）迅即以其通曉之語言，詳細告知被控罪名及案由；（二）給予充分之時間及便利，準備答辯並與其選任之辯護人聯絡；（三）立即受審，不得無故稽延；（四）到庭受審，及親自答辯或由其選任辯護人答辯；未經選任辯護人者，應告以有此權利；法院認為審判有此必要時，應為其指定公設辯護人，如被告無資力酬償，得免付之；（五）得親自或間接詰問他造證人，並得聲請法院傳喚其證人在與他造證人同等條件下出庭作證；（六）如不通曉或不能使用法院所用之語言，應免費為備通譯協助之；（七）不得強迫被告自供或認罪。四、少年之審判，應顧念被告年齡及宜使其重適社會生活，而酌定程序。五、經判定犯罪者，有權聲請上級法院依法覆判其有罪判決及所科刑罰。六、經終局判決判定犯罪，如後因提出新證據或因發見新證據，確實證明原判錯誤而經撤銷原判或免刑者，除經證明有關證據之未能及時披露，應由其本人全部或局部負責者外，因此判決而服刑之人應依法受損害賠償。七、任何人依一國法律及刑事程序經終局判決判定有罪或無罪開釋者，不得就同一罪名再予審判或科刑。」

於國際人權法之領域中，公平審判權（right to a fair trial）不只是特定英美法或大陸法體系所重視，而已然為普世價值。除公政公約之外，諸多國際人權公約，包括聯合國及區域性人權公約均有所規定，譬如，制定時間於公政公約之前的1950年《歐洲人權公約》（European Convention on Human Rights）第6條；再如制定於公政公約之後的1969年《美洲人權公約》（American Convention on Human Rights）第8條、1981年《非洲人權與民族權利憲章》（Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights）第7條均是。

至於公政公約的部分則是第14條公平審判條款，此條款規定了一連串的程序保障規定，諸如公開審判、告知罪名、無罪推定、選任辯護人、詰問證人、不自證其罪、自白之任意性、審級救濟、刑事補償、一事不再理、通譯協助、少年保護等等，合計7項。其中，公政公約第14條第1項乃一般性之程序要求：「人人在法院或法庭之前，悉屬平等。任何人受刑事控告或因其權利義務涉訟須予判定時，應有權受獨立無私之法定管轄法庭公正公開審問。……」即此項之程序保障並不限於刑事程序，而係包含權利義務爭訟等程序；第2項則是刑事被告應受無罪推定保障：「受刑事控告之人，未經依法確定有罪以前，應假定其無罪。」；第3項則是刑事被告之最低限度權利保障：「審判被控刑事罪時，被告一律有權平等享受下列最低限度之保障：……」。以上3項大致同於《歐洲人權公約》第6條公平審判條款⁵⁸，而公政公約第14條第4至7項也都是針對刑事程序而來。

⁵⁸ 歐洲人權公約第6條：「一、在決定某人的公民權利與義務或在決定對某人的任何刑事罪名時，任何人有權在合理的時間內受到依法設立的獨立與公正的法庭之公平與公開的審訊。判決應公開宣布，但為了民主社會中的道德、公共秩序或國家安全的利益，而該社會中為了少年的利益或保護當事各方的私生活有此要求，或法院認為在其種特殊的情況下公開將有損於公平的利益而堅持有此需要，可以拒絕記者與公眾旁聽全部或部分的審判。二、凡受刑事罪的控告者在未經依法證明有罪之前，應被推定為無罪。三、凡受刑事罪的控告者具有下列最低限度的權利：（一）立即以他所能了解的語文並詳細地告以他被控的性質

就公政公約第14條公平審判之意涵，人權事務委員會曾於公政公約第32號一般性意見第2至4段中表示：「2. 在法院和法庭前一律平等和獲得公正審判的權利是人權保護的一項關鍵內容，是保障法治的一項程序手段。《公約》第十四條旨在確保司法制度的適當運作，並為此保障一系列具體權利。3. 第十四條的性質複雜，混合了適用範圍各不相同的各種保障。第一項第一句規定在法院和法庭前一律平等的一般保障，不論在這些機構的訴訟性質如何。同項第二句規定在任何人受刑事控告或因其權利義務涉訟須予判定時，有權受獨立無私之法定管轄法庭公正公開審問。在這些審問中，只能根據第一項第三句所規定的具體情況，才可拒絕媒體和公眾出席旁聽。該條第二項至第五項列出了受刑事控告者可以利用的程序保障。第六項規定在刑事案件中出現誤審可獲得賠償的實質權利。第七項規定一罪不二審，從而對自由提供實質保障，即個人有權就經終局判決判定有罪或無罪開釋者，不得就同一罪名再予審判或科刑。《公約》締約國在其報告中，應明確區分公正審判權的各個不同方面。4. 第十四條列出了締約國必須尊重的各種保障，不論他們的法律傳統和國內法如何。締約國應報告如何依據其各自的法律制度解釋這些保障，委員會則指出，委員會無法任由國內法確定《公約》保障的實質性內容。⁵⁹」

和原因；(二) 為準備辯護，應有適當的時間和便利；(三) 由他本人或由他自己選擇的法律協助為自己進行辯護，或如果他無力支付法律協助的費用，則為公平的利益所要求時，可予免費；(四) 訊問不利於他的證人，並在與不利於他的證人相同的條件下，使有利於他的證人出庭受訊；(五) 如果他不學或不會講法院所使用的語文，可以請求免費的譯員協助。」就公政公約第14條第4至7項之刑事程序保障等規定，歐洲人權公約約文本雖並未規範，但後來即以議定書之方式將之納入保障，例如《歐洲人權公約第七附加議定書》第2至4條規定，其中，刑事案件救濟權即規定於議定書第2條第1項。參見Helmut Satzger著，王士帆譯，國際刑法與歐洲刑法，頁343（2014年）。

⁵⁹ Human Rights Committee, General Comment No. 32, CCPR/C/GC/32 (2007), para. 2-4.

於此結構關係下，就公政公約公平審判之規定，有文獻認為，從公政公約整體上看，其實隱含著程序保障位階之問題，因為公政公約第14條第1項所規定者是適用到所有各類程序，但其他項則只適用至刑事程序，足見就立法論上來看，公政公約對於刑事程序之要求是較高的⁶⁰，甚且，因有關刑事審級救濟制度，既然國際人權公約特予以明文規定，則此必須有更高於一般法律規範保障，而不是單純法律規定便可以解決的⁶¹。

此外，若將公政公約第14條公平審判權利之相關規定對應於我國既有的刑事法規中可發現，大多係明訂於我國刑事訴訟法以及少年事件處理法當中，依此，具國內法效力之公政公約中所揭示的相關規定就成為了一個觀察基點，因為除了公政公約本身即應被適用之外，從此基點出發，亦可觀察國內既有刑事規制和公政公約間的落差，乃至於相關法院裁判能否達到公政公約的基本要求。實則，國內近年來也有文獻開始以公約內國法化之觀點就該等落差提出觀察及評論⁶²。例如，單就公政公約公平審判條款之於我國刑事規制，即可討論刑事訴訟當中諸如法官迴避問題、被告緘默權、辯護制度、訴訟上的照料義務、證據使用禁止之解釋適用等題目⁶³。

60 林超駿，論合憲訴訟救濟制度之建構——從釋字第665號解釋出發，臺北大學法學論叢，82期，頁63（2012年）。

61 林超駿（註27），頁378。

62 例見：林鈺雄，2015年刑事程序法裁判回顧：從國際人權公約內國法化的觀點出發，臺大法學論叢，45卷特刊，頁1649-1678（2016年）；林鈺雄，2014年刑事程序法裁判回顧：從國際人權公約內國法化的觀點出發，臺大法學論叢，44卷特刊，頁1535-1566（2015年）；林鈺雄，2013年刑事程序法發展回顧：從國際人權公約內國法化的觀點出發，臺大法學論叢，43卷特刊，頁1265-1298（2014年）；林鈺雄（註56），頁1067-1107。林鈺雄教授近年該等以國際人權公約角度檢視我國最高法院裁判之裁判回顧系列文章，相當精彩，誠值參照。

63 具體例示如：公政公約第14條第1項公正法院規定之於刑事訴訟法第17條、第18條的中立性、無偏頗性（impartiality）等迴避規定；公政公約第14條第3項第3款「審判被控刑事罪時，被告一律有權平等享受下列最低限度之保障：……三、立即受審，不得無故稽延」規定之於刑事妥速審判法第7條減刑規定；公政公約第14條第3項第5款「得親自或間接詰問他造證人，並得聲請法院傳喚其

四、小結

據此，本文認為，就兩公約成為國內法之一部分，當有一元論、二元論，以及兩公約以何種形式引入我國法等爭議，不過，因我國已於2009年制定兩公約施行法明文承認兩公約有關保障人權之規定具有國內法律效力，因此，對於兩公約而言，該等爭議已無太大的區別實益。就法位階之部分，公政公約有關人權保障之規定，在我國法原則上至少屬相當、甚至高於國會法律之位階，一般法院有適用義務。又即便不承認公約相對於一般法律之優先優位性，也無礙於法官於具體個案中運用「合乎公約之內國法解釋」來避免公約權利保障和國內既有刑事法制間的衝突，否則，法官自身亦會違反兩公約施行法第2、3條等規定。另一方面，自前揭析論亦可發現，諸多國際人權公約，包括聯合國及區域性人權公約均有就公平審判（fair trial）有所規定，而公政公約第14條第5項覆判權利規定即屬此公政公約公平審判架構下的一環。至於該條項之規定內涵或解釋，以及如何和我國刑事訴訟法第376條之刑事上訴三審限制條款作比較適用，以下即從人權事務委員會之相關解釋繼續論之。

肆、公政公約第14條第5項規定之解釋及適用： 以人權事務委員會相關解釋論之

在公政公約中，與上訴權／覆判權有關的規定主要就是公政公約第14條第5項：「經判定犯罪者，有權聲請上級法院依法覆判其有罪判決及所科刑罰。」

證人在與他造證人同等條件下出庭作證」規定之於我國對質詰問之相關實務意見及規定等題目。

相較於公政公約第14條第5項規定，於區域性人權公約中，1969年《美洲人權公約》第8條第2項第8款「有權向更高一級的法院上訴。」（the right to appeal the judgment to a higher court）以及1984年的《歐洲人權公約第七附加議定書》第2條第1項前段「被法庭判決為犯有刑罰罪的任何人均有權要求上一級法院對判決或判刑進行複審...」（Everyone convicted of a criminal offence by a tribunal shall have the right to have his conviction or sentence reviewed by a higher tribunal...）也都有類似規定⁶⁴。

然而公政公約第14條第5項規定有意地採用了較為一般性的措辭表達，究其原因乃，公政公約之該條項規定是以1959年以色列在聯合國大會第三委員會提出之建議為基礎⁶⁵，而當時的以色列代表Baror反覆地強調：「他所感興趣的只是承認上訴權的原則，至於上訴的方式（type of appeal）則繫諸於各個法律制度自行決定。⁶⁶」

不過，若要了解此規定之具體意涵和適用要件，則必須自人權事務委員會所作成之一般性意見、個人申訴決定以及其審查各國報告所作成之結論性意見等相關解釋。蓋按兩公約施行法第3條規定，適用公政公約規定，應參照公政公約之立法意旨及人權事務委員會對公約規定之解釋，而就公政公約而言，人權事務委員會具有對公約權利提出解釋之權，並已累積許多適用上的解釋案件及文獻，實則，對初步開始實踐兩項人權公約之我國政府機關，特別是

64 不過，《歐洲人權公約第七附加議定書》第2條第2項規定了限制可能，即：「在法律規定的輕度犯罪，或在所涉人員最初即在最高法院判決或是在不服無罪判決的上訴後判決的情況下，本權利可有例外。」（This right may be subject to exceptions in regard to offences of a minor character, as prescribed by law, or in cases in which the person concerned was tried in the first instance by the highest tribunal or was convicted following an appeal against acquittal.）See STEFAN TRECHSEL, HUMAN RIGHTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 362 (2005).

65 MANFRED NOWAK, U.N. COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS: CCPR COMMENTARY 266 (2d ed. 2005).

66 TRECHSEL, *supra* note 64, at 361.

司法機關來說，更應依此等方式對人權公約進行解釋，以正確探求各項公約規定所保障之自由及權利內涵與國家對此義務內涵之實踐。

一、依法覆判權利之實質保障

首先，就依法覆判之意涵，可參見公政公約第32號一般性意見第45段即：「《公約》第十四條第五項規定，凡被判定有罪者，有權聲請上級法院依法覆判其有罪判決及所科刑罰。如各種不同語言的用詞表述（*crime*、*infractio*n、*delito*）顯示，該保障不僅限於情節最重大之罪。既然這是《公約》承認的權利，並非僅由國內法規定，因此本條中的『依法』一詞並非旨在將覆判的根本權利交由締約國任意決定。依法的措詞實際上涉及到確定上級法院的覆判方式，以及哪一法院根據《公約》有責任進行覆判。第十四條第五項不要求各締約國規定多級上訴。然而該項提到國內法；這應解釋為：如果國內法提供了更多級的上訴，為有罪判決者必須能夠有效向每層級提出上訴。⁶⁷」

從該一般性意見可知，覆判權利於公政公約的脈絡底下，至少有以下三點應予以注意：

⁶⁷ Human Rights Committee, General Comment No. 32, *supra* note 53, at para. 45: “Article 14, paragraph 5 of the Covenant provides that anyone convicted of a crime shall have the right to have their conviction and sentence reviewed by a higher tribunal according to law. As the different language versions (*crime*, *infractio*n, *delito*) show, the guarantee is not confined to the most serious offences. The expression ‘according to law’ in this provision is not intended to leave the very existence of the right of review to the discretion of the States parties, since this right is recognised by the Covenant, and not merely by domestic law. The term according to law rather relates to the determination of the modalities by which the review by a higher tribunal is to be carried out, as well as which court is responsible for carrying out a review in accordance with the Covenant. Article 14, paragraph 5 does not require States parties to provide for several instances of appeal. However, the reference to domestic law in this provision is to be interpreted to mean that if domestic law provides for further instances of appeal, the convicted person must have effective access to each of them.”

（一）覆判權利之保障並不限於重罪

凡被判定有罪者，即有權聲請上級法院依法覆判其有罪判決及所科刑罰，且按人權事務委員會之解釋意見亦明確指出，該權利保障並不限於情節最重大之罪。亦即不論罪之輕重，只要是被判定犯罪，則該被判定有罪之人即有向上級法院聲請依法覆判之權利。

此外，覆判權利適用於所有類型之犯罪，而不僅僅是用於重罪此一解釋亦可從公政公約第14條第5項的準備材料（*travaux préparatoires*）中予以確認，蓋最初以色列提出的草案建議曾將微罪作為上訴權之例外，惟隨後經斯里蘭卡的動議而將此一例外予以取消⁶⁸。

（二）「依法」一詞並非旨在將覆判的根本權利交由締約國任意決定

「依法」（*according to law*）一詞並非旨在將覆判的根本權利交由締約國任意決定，而只是給予各締約國得以視其具體社會法制等情形調整其刑事上訴制度之設計以因應各國制度之不同⁶⁹。又公政公約第14條第5項規定乃強調「依法」，條文中亦未見上訴（*appeal*）字眼，但此一規定中強調由更上級法院（*a higher tribunal*）審查，是此係賦予人民上訴之權限，並無疑問，換言之，縱使締約國自稱個案已依其國內既有的法律而不得上訴，亦不可據此逕予認定其個案就無公政公約覆判權利保障之違反問題。

人權事務委員會亦曾於其一般性意見中特別強調，就公政公約第14條公平審判條款所列出之各該權利保障的解釋適用，締約國應

⁶⁸ NOWAK, *supra* note 65, at 267.

⁶⁹ ALEX CONTE & RICHARD BURCHILL, *DEFINING CIVIL AND POLITICAL RIGHTS: THE JURISPRUDENCE OF THE UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COMMITTEE* 194 (2d ed. 2009).

報告其係如何依據其各自的法律制度解釋這些公約權利保障，而公約保障的實質性內容（essential content）並不能任由締約國之國內法任意解釋及確定。事實上，就「禁止任由締約國之國內法任意解釋及確定公約權利」乙事，人權事務委員會也認為此並不限於公政公約第14條第5項覆判權利規定，而是普遍性地適用於公政公約第14條公平審判條款當中⁷⁰。

再如，於人權事務委員會所處理之個人申訴案例 *Salgar de Montejo v. Colombia* 案中，該案申訴人所犯罪行，依哥倫比亞國內法不屬於應予覆審之範圍，對此，哥倫比亞主張「若依照其國內法已明訂不得上訴之案件，即無違反依法覆判之問題」，不過，人權事務委員會駁斥該主張並表示哥倫比亞之行為違反了公約，因為公政公約第14條第5項中「依法」一詞的涵義並不是讓締約國根據自己的法律自由裁量應予覆審的案件範圍，且上訴權乃由公約所明文承認的權利，進而認定該案違反了公政公約第14條第5項規定⁷¹。

⁷⁰ Human Rights Committee, General Comment No. 32, *supra* note 59, at para. 4: “Article 14 contains guarantees that States parties must respect, regardless of their legal traditions and their domestic law. While they should report on how these guarantees are interpreted in relation to their respective legal systems, the Committee notes that it cannot be left to the sole discretion of domestic law to determine the essential content of Covenant guarantees.”

⁷¹ Human Rights Committee, *Consuelo Salgar de Montejo v. Colombia*, Communication No. 64/1979, U.N. Doc. CCPR/C/OP/1 at 127 (1985), para. 10.4: “The Committee considers that the expression ‘according to law’ in article 14 (5) of the Covenant is not intended to leave the very existence of the right of review to the discretion of the States parties, since the rights are those recognized by the Covenant, and not merely those recognized by domestic law. Rather, what is to be determined ‘according to law’ is the modalities by which the review by a higher tribunal is to be carried out. It is true that the Spanish text of article 14 (5), which provides for the right to review, refers only to ‘un delito’, while the English text refers to a ‘crime’ and the French text refers to ‘une infraction’ Nevertheless the Committee is of the view that the sentence of imprisonment imposed on Mrs. Consuelo Salgar de Montejo, even though for an offence defined as ‘contravencion’ in domestic law, is serious enough, in all the circumstances, to require a review by a higher tribunal as provided for in article 14 (5) of the Covenant.”

（三）有罪判決者必須能夠有效向每層級提出上訴

另外，公政公約第14條第5項亦非要求各締約國規定多級上訴，而是認為若國內法提供了更多級的上訴，則受有罪判決者必須能夠有效地向其上級法院提出上訴以確保其覆審權利。

譬如在*Henry v. Jamaica*案中，申訴人Henry主張由於無法得到牙買加上訴法院之書面判決，此實際上剝奪了其向英國樞密院司法委員會上訴之權利，蓋該司法委員會通常不受理「未附下級法院書面」之上訴。對此，人權事務委員會認為，公政公約第14條第5項並非要求各締約國應規定多級上訴，但若國內法提供了進一步的上訴審級，則受有罪判決者應當能夠有效地利用該等上訴審級，以確保其覆審權利，而牙買加上訴法院未作出書面判決，乃現實上剝奪了申訴人向英國樞密院司法委員會上訴之權利，此有違申訴人之公政公約第14條第5項覆審權利⁷²。

二、適用之程序範圍

就公政公約第14條第5項之適用程序部分，可參公政公約第32號一般性意見第46段：「第十四條第五項並不適用於法律訴訟中確定權利和義務的程序或刑法上訴審理之外的任何其他程序，比如關於憲法權利的申訴。⁷³」

從公政公約第14條第5項之規定「經判定犯罪者……」及上揭人權事務委員會解釋意見可知，公政公約第14條第5項依法覆判之

⁷² Human Rights Committee, *Henry v. Jamaica*, Communication No. 230/1987, U.N. Doc. CCPR/C/43/D/230/1987 (1991), para. 8.4.

⁷³ Human Rights Committee, General Comment No. 32, *supra* note 59, at para. 46: “Article 14, paragraph 5 does not apply to procedures determining rights and obligations in a suit at law or any other procedure not being part of a criminal appeal process, such as constitutional motions.”

權利係針對「刑事案件」之程序保障而言⁷⁴。其他諸如純粹確定權利義務法律關係之爭訟⁷⁵（如民事訴訟），或者是憲法訴訟⁷⁶（如於我國的大法官釋憲聲請程序⁷⁷），均非公政公約第14條第5項依法覆判之權利程序適用範圍⁷⁸。

應特別注意者係，公政公約第14條第5項和第2條第3項間之關係。公政公約第2條第3項：「**本公約締約國承允：（一）確保任何人所享本公約確認之權利或自由如遭受侵害，均獲有效之救濟，公務員執行職務所犯之侵權行為，亦不例外（二）確保上項救濟聲請人之救濟權利，由主管司法、行政或立法當局裁定，或由該國法律制度規定之其他主管當局裁定，並推廣司法救濟之機會；（三）確保上項救濟一經核准，主管當局概予執行。**」（粗體為作者強調）。乃有效救濟權（right to an effective remedy）之規定。對此，人權事務委員會曾表示，一旦個案出現違反公政公約第14條公平審判條款之情況，均應當遵守該條規定，然而，就「由上級法院覆判為有罪判決和判刑」之情形，當個案當事人援引此等向上級法院上訴的權利時，則此時公政公約第14條第5項規定相對於第2條第3項規定即具有特別法（*lex specialis*）之性質，就此，人權事務委員會曾在 *Jesús Terrón v. Spain* 案中具體裁示，因人權事務委員會已就西班牙違反公政公約第14條第5項規定之部分為受理，且公政公約第14條第5項規定乃第2條第3項之特別法，因此，人權事務委員會不必再就申訴人

74 JOSEPH & CASTAN, *supra* note 3, at 508.

75 Human Rights Committee, I. P. v. Finland, Communication No. 450/1991, U.N. Doc. CCPR/C/48/D/450/1991 (1993), para. 6.2.

76 Human Rights Committee, Douglas, Gentles and Kerr v. Jamaica, Communication No. 352/1989, U.N. Doc. CCPR/C/49/D/352/1989 (1993), para. 11.2.

77 當然，若該締約國之憲法權利申訴制度之設計本身即屬該國刑事上訴制度之一部分者（譬如其內國的刑事終審法院同時也是憲法法院），則另當別論。

78 就此適用程序範圍之異同，可比較公政公約第14條第1項公正法院之規定。亦即公政公約第14條第1項之程序保障並不限於刑事程序，而係包含權利義務爭訟等程序。

指稱違反公政公約第2條第3項規定之部分作出決定⁷⁹。

三、違反公政公約第14條第5項之具體例示

實則，人權事務委員會曾於公政公約第32號一般性意見第47段⁸⁰中具體舉例以下幾種違反公政公約第14條第5項之情況：

（一）一審法院判決即終審判決

一審判決即為終審判決。人權事務委員會於 *Gelazauskas v. Lithuania* 案中曾表示，在一個締約國的最高法院審理一審刑事案件乃違背公約規定的精神，此事實上剝奪了在一審程序中被判定有罪者由高一級法庭覆審的權利，亦即，當一國的最高法院既是第一審又是唯一審判法院時，此即違反向上級法院請求覆判之權利規定⁸¹。

又如於 *Jesús Terrón v. Spain* 案中⁸²，申訴人 *Jesús Terrón* 為西班牙之區域議會議員，其涉及偽造文書罪嫌，惟按西班牙國內法規

79 Human Rights Committee, *Jesús Terrón v. Spain*, Communication No. 1073/2002, U.N. Doc. CCPR/C/82/D/1073/2002 (2004), para. 6.6: “The Committee’s established jurisprudence states that article 14, paragraph 5, of the Covenant is a *lex specialis* in relation to article 2, paragraph 3 (a) of the Covenant, such that since the Committee has decided that the alleged violation of article 14, paragraph 5, is admissible, it is unnecessary for it to take a decision on the alleged violation of article 2, paragraph 3, of the Covenant.”

80 Human Rights Committee, General Comment No. 32, *supra* note 59, at para. 47: “Article 14, paragraph 5 is violated not only if the decision by the court of first instance is final, but also where a conviction imposed by an appeal court or a court of final instance, following acquittal by a lower court, according to domestic law, cannot be reviewed by a higher court. Where the highest court of a country acts as first and only instance, the absence of any right to review by a higher tribunal is not offset by the fact of being tried by the supreme tribunal of the State party concerned; rather, such a system is incompatible with the Covenant, unless the State party concerned has made a reservation to this effect.”

81 Human Rights Committee, *Kestutis Gelazauskas v. Lithuania*, Communication No. 836/1998, U.N. Doc. CCPR/C/77/D/836/1998 (1997), para. 7.2, 7.6.

82 Human Rights Committee, *Jesús Terrón v. Spain*, Communication No. 1073/2002, *supra* note 79, at para. 7.4.

定，因其議員身分之關係，案件乃直接由西班牙最高法院審判，後來申訴人被西班牙最高法院判處兩年徒刑及賠償10萬比塞塔（*peseta*），且按西班牙內國法律，申訴人並無聲請司法覆審之權利。對於申訴人而言，其一審法院判決即為終審法院判決。就此，人權事務委員會表示，在某些情況下，因某一個人的職位的關係而使其應由較高級法院審理此人的案件，這與一般情況不同，但僅僅是這種情況，並不會妨礙被告要求法院對其定罪及刑罰進行覆審之權利，因此，人權事務委員會認定本案之此種情形已違反了公政公約第14條第5項規定。

（二）下級法院諭知無罪判決後，上訴判決改判有罪且按國內法不得上訴

違反公政公約第14條第5項的情況不僅包括第一審法院判決即為終審判決之情形，而且還包括當下級法院宣判無罪後，上級法院或終審法院更為有罪判決，但依照國內法規定無法再繼續向上級法院請求覆判之情形，此亦屬違反公政公約第14條第5項的典型態樣之一。

於*Gomariz Valera v. Spain*案中，申訴人*Gomariz Valera*遭控涉貪污罪嫌，嗣經一審法院判處無罪、上級法院改判有罪，不過，按西班牙刑事訴訟程序規定，如果上訴法院是最初對被告定罪的法院，則不允許被告就該上訴法院所做的定罪判刑決定提起上訴⁸³。對此，人權事務委員會認為，公政公約第14條第5項覆審權利不僅包含確保被告能向上一級法院提交判決，也應確保就定罪的部分能進行第二次覆審，不過人權事務委員會認為這一點在本案中並沒有做到，而且在締約國未就該條款作出保留之情況下，被告要求上級法院對其定罪及刑罰進行覆審之權利不得受到任何減損，因此，人權

⁸³ Human Rights Committee, *Gomariz Valera v. Spain*, Communication No. 1095/2002, U.N. Doc. CCPR/C/84/D/1095/2002 (2005), para. 3.3.

事務委員會認為本件之情況有違公政公約第14條第5項之規定⁸⁴。

四、小結

從上開人權事務委員會相關解釋意見可以發現，其對公政公約第14條第5項依法覆判實質保障權利，強調了以下幾個觀念：（1）覆判權利之保障並不限於重罪；（2）「依法」一詞並非旨在將覆判的根本權利交由締約國任意決定；（3）有罪判決者必須能夠有效地向每層級提出上訴。

又公政公約第14條第5項所適用程序範圍主要係就刑事案件之程序保障。而人權事務委員會亦具體舉出違反公政公約第14條第5項之例子即：「一審法院判決即終審判決」、「下級法院諭知無罪判決後，上訴判決改判有罪且按國內法不得上訴」。

若將公政公約第14條第5項對應於我國刑事訴訟法第376條上訴三審限制規定，並按一審、二審判決結果態樣（有罪、無罪）說明其間之公約關聯性，則可排列組合如下（表1）：

⁸⁴ *Id.* at para. 7.1.

表1 我國刑事訴訟法第376條上訴限制態樣及其公約關聯性

	一審判決	二審判決	公約關聯性
1	有罪	有罪	一、二審判決結果均有罪，公政公約第14條第5項並非要求各締約國規定多級上訴，惟我國設有「三級三審」審級制度，仍應提供被告公平、有效的上訴機會
2	無罪	無罪	一、二審判決結果均無罪，被告並非「經判定犯罪者」，無公政公約第14條第5項之問題
3	有罪	無罪	二審判決結果為無罪，被告並非「經判定犯罪者」，無公政公約第14條第5項之問題
4	無罪	有罪	二審判決結果為有罪，被告為「經判定犯罪者」，受公政公約第14條第5項權利保障

資料來源：作者製表。

就「一審法院諭知有罪判決，二審判決仍維持有罪」之情況（表1之1）是否有覆判權利違反的問題。人權事務委員會曾於其一般性意見中表示「如果上級法院詳盡地審查了對為有罪判決者的指控，考量了在審判和上訴時提交的證據，發現具體案件中有足夠犯罪證據而證明有罪，就不違反《公約》。⁸⁵」且如前揭一般性意見意旨所示，公政公約第14條第5項並不要求各締約國規定多級上訴⁸⁶，因此不能推論出締約國應設立多重的審級以供救濟之結論，不過，若按締約國之國內法本身即設有多重上訴之審級制度者，那麼就要提供被告公平、有效的上訴機會⁸⁷。

85 Human Rights Committee, General Comment No. 32, *supra* note 59, at para. 48.

86 Human Rights Committee, Leon R. Rouse v. Philippines, Communication No. 1089/2002, U.N. Doc. CCPR/C/84/D/1089/2002 (2005), para. 7.6.

87 Human Rights Committee, Henry v. Jamaica, Communication No. 230/1987, *supra* note 72, at para. 8.4: “The Committee observes that the Covenant does not require States parties to provide for several instances of appeal. However, the words ‘according to law’ in article 14, paragraph 5, are to be interpreted to mean that if domestic law provides for further instances of appeal, the convicted person must have effective access to each of them.”

又若一、二審之判決結果均為無罪嗣不得上訴三審者，因被告並非「經判定犯罪者」，自無公政公約第14條第5項之問題（表1之2）。若係一審法院諭知有罪判決後二審判決改判無罪且按國內法不得上訴者，則因二審判決結果為無罪，被告並非「經判定犯罪者」，此亦無違反公政公約依法覆判權利之問題（表1之3）。

至於經一審判決被告無罪，但二審撤銷原審判決而自為有罪判決者，不得上訴於第三審法院之情形（表1之4），如前所述，違反公政公約第14條第5項的典型態樣不僅包括第一審法院判決即為終審判決之情形，而且還包括當下級法院宣判無罪後，上級法院或終審法院更為有罪判決但依照國內法規定無法再繼續向上級法院請求覆判之情形，因此，此即屬違反公政公約第14條第5項的典型態樣。

我國刑事訴訟法第376條排除「微罪」案件覆判權利之規定，個案即可能發生從一審無罪到二審改判有罪而不得上訴三審之情形，而此顯然正是人權事務委員會所指出違反公政公約第14條第5項規定之具體示例。事實上，我國依照兩公約施行法第6條⁸⁸規定，第一次邀請國際獨立專家來臺審查國家報告時，專家就已經注意到我國刑事訴訟法第376條排除「微罪」案件覆判權利違反公政公約之問題，即其於結論性意見第65段指出：「根據公政公約第14條第5項，經判定犯罪者，有權聲請上級法院依法覆判其有罪判決及所科刑罰。在實務上，刑事訴訟法第376條規定某些案件類型不得上訴至第三審法院。在這類案件，被告第一審法院被判無罪而在第二審法院被判有罪，就沒有上訴救濟的機會，這違反公政公約第14條第5項的規定。專家因此建議修訂刑事訴訟法第376條，讓每位第一審法院被判無罪但第二審法院被判有罪之被告，都有權利上訴至第三審法院。另外，應修訂刑事訴訟法第388條，要求指定辯護人給希望就刑事有罪判決上訴至第三審法院卻沒有辯護人的被

⁸⁸ 兩公約施行法第6條：「政府應依兩公約規定，建立人權報告制度。」

告。⁸⁹」(粗體為作者強調)。甚者，於2017年1月，國際專家對我國政府關於落實兩公約第二次報告之審查，於該次結論性意見與建議第69段再次指出：「2013年審查委員會曾建議，為維護公政公約第14條第5項所規定經判定犯罪者聲請上級法院依法覆判的權利，刑事訴訟法第376條應予修正，以保障每位第一審法院判決無罪，但在第二審法院被判決有罪之被告，皆有上訴至第三審法院的權利。此外，委員會建議修正刑事訴訟法第388條，要求任何無選任辯護人而有意對其判決上訴至第三審法院的被告強制指定辯護。但4年後，立法院卻仍未能遵循這些建議。審查委員會迫切要求立法院尊重這些建議。⁹⁰」(粗體為作者強調)。

89 原文為：“65. According to Article 14 (5) ICCPR, everyone convicted of a crime shall have the right to his or her conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal. In practice, Article 376 of the Code of Criminal Procedure provides that certain types of cases may not be appealed to the court of third instance. **In such cases, a criminal defendant, having been found not guilty in the first trial but guilty in the second instance, is thereafter denied the opportunity of appellate relief, in violation of Article 14 (5) ICCPR. The Experts, therefore, recommend that Article 376 of the Code of Criminal Procedure be amended so that every defendant found guilty in the court of second instance after a not guilty verdict in the court of first instance will be guaranteed the right of appeal to the court of third instance.** In addition, Article 388 of the Code of Criminal Procedure shall be amended to require the appointment of counsel for any defendant who lacks counsel and wishes to appeal his criminal conviction to the court of third instance.” 參見對中華民國（臺灣）政府落實國際人權公約初次報告之審查國際獨立專家通過的結論性意見與建議，法務部，<https://www.humanrights.moj.gov.tw/media/12490/312259531585.pdf?mediaDL=true>（最後瀏覽日：2021年11月1日）。

90 原文為：“69. **In 2013, the Review Committee recommended, in order to vindicate the right to higher review of any criminal conviction prescribed by Article 14 (5) ICCPR, that Article 376 of the Code of Criminal Procedure (CCP) be amended so that every defendant found guilty in the court of second instance after a not guilty verdict in the court of first instance be guaranteed the right to appeal to the court of third instance.** Moreover, the Committee recommended that Article 388 of the CCP be amended to require the appointment of counsel for any defendant who lacks counsel and wishes to appeal his conviction to the court of third instance. **Yet, four years later, the Legislative Yuan has failed to comply with these recommendations. The Review Committee urgently requests the Legislative Yuan to respect its recommendations.**” 參見對中華民國（臺灣）政

另自2012年至2017年6月一審判決無罪，二審判決有罪而不得上訴第三審之案件統計數據（表2）可知，自2012年以來，於我國每年約莫有三百餘件，此等因不得上訴所可能造成的訴訟權益侵害案件，實不容小覷。

表2 2012年至2017年6月一審判決無罪，二審判決有罪而不得上訴第三審之案件統計

單位：件

	總計	臺灣高等法院	臺中高分院	臺南高分院	高雄高分院	花蓮高分院	金門高分院
2012年	375	203	52	38	74	7	1
2013年	368	184	65	29	76	14	-
2014年	342	158	72	40	56	15	1
2015年	301	125	57	44	56	18	1
2016年	398	202	64	58	59	14	1
2017年(1-6月)	143	78	25	15	21	4	-

資料來源：司法院。作者製表。

說明：一審判決無罪、二審判決有罪均以被告最重罪判斷。一案數被告，其中有一被告符合一審無罪、二審有罪之條件，且全案或部分案件不得上訴，即計入本表。

不過，更值得探究的應當是，既然刑事訴訟法第376條或公政公約第14條第5項規定兩者同為「現行法」，那麼我國裁判實務於具體個案中又是採取如何的立場及意見，此等誠值深入探究，本文以下即繼續就我國裁判實務意見為分析檢討。

府關於落實國際人權公約第二次報告之審查國際審查委員會通過的結論性意見與建議，法務部，<https://www.humanrights.moj.gov.tw/media/12295/3552004141607ed2b9.pdf?mediaDL=true>（最後瀏覽日：2021年11月1日）。

伍、最高法院相關刑事裁判及司法院釋字第752號解釋之檢討：以「一審無罪、二審改判有罪」之案件為例

因本文所研究之案件主要係「從一審無罪到二審改判有罪而不得上訴三審」之案例情狀，因此，若欲探究相關法院裁判實務意見者，則應當是以三審法院即最高法院之裁判為主。又據本文以關鍵字檢索司法院法學資料檢索系統⁹¹發現，自2009年12月兩公約施行截至2017年8月底，我國最高法院對此表示意見者僅有二則裁判：最高法院102年度台上字第4532號刑事判決（裁判日期：2013年11月7日）以及最高法院103年度台上字第216號刑事判決（裁判日期：2014年1月16日）；另一方面，2017年7月28日，大法官就刑事訴訟法第376條第1、2款所作成司法院釋字第752號解釋，因該號解釋內容與本文所提出之刑事上訴三審限制疑義直接相關。是以下先就兩則判決之案例事實與判決要旨，以及司法院釋字第752號解釋之事實背景、解釋文及解釋理由等說明後，再為綜合評釋。

一、最高法院102年度台上字第4532號刑事判決

（一）案例事實

最高法院102年度台上字第4532號刑事判決⁹²（下稱【判決一】）之案例事實為：

吳○儀、丁○鈞、李○慧為壹傳媒出版有限公司之記者小組成員，三人於2012年5月初共同撰寫標題文字為「美女事務官簡訊噲

91 司法院法學資料檢索系統，<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>（最後瀏覽日：2021年11月1日）。

92 歷審判決：臺灣臺北地方法院101年度自字第67號刑事判決、臺灣高等法院102年度上易字第83號刑事判決、最高法院102年度台上字第4532號刑事判決（上訴駁回）。

洪妻，名檢洪○華爆新桃花」之報導則，其中提及「本刊接獲爆料，原來李○倫捲入一起桃色風暴，而事件的男主角，是她高檢署的同事、風流情史不斷的檢察官洪○華。風暴的起因，則是一封內容『鹹濕露骨』的簡訊。」「這封簡訊是由李○倫傳給洪○華的第二任妻子劉○瑄，內容是『你老公說妳在床上像隻死魚！』美女事務官口氣酸溜溜，批評洪妻床技不如人。洪妻收到簡訊之後，大為光火，立刻找上洪○華的頂頭上司、高檢署檢察長顏○和」、「近日最高檢察署及台北地檢署同時收到檢舉函，指稱『性好漁色的檢察官，沾上高檢署也是一位『官』的美女，小三還嗆小三，嘲笑人家床技不如人……』」、「風流名檢花邊多」、「本刊調查，除了李女外，洪○華也和一些女性傳出曖昧，其風流情史早傳遍檢察界」、「洪○華也因風紀問題，自請降調為檢察官，如今再傳出新桃花，可能連長官都不知道該怎麼處理了！」等內容文字；並指示不知情之壹傳媒公司繪圖人員唐○璘、許○源二人，以電腦繪製模擬情境之圖畫二則，吳○儀再分別於該二則圖畫下分別註記「嘲諷床技，美女事務官李○倫傳簡訊給洪○華第二任妻子，嘲諷洪妻床技不如人。」、「髮妻告官，洪妻氣沖沖向高檢檢察長顏○和檢舉，顏○和立刻將李○倫調職回北檢。」等報導內容，交由不知情之壹傳媒公司人員作業，刊登於出刊日為2012年5月10日之第572期壹週刊紙本刊物，於2012年5月9日上午即透過各大書局、便利商店、書報攤等對外販售供不特定人購買閱悉。

案經洪○華、劉○瑄向臺灣臺北地方法院提起自訴，一審判決被告無罪，自訴人不服一審判決，提起上訴，二審撤銷原判決，認定被告等人犯共同犯散布文字圖畫誹謗罪。被告等人不服二審判決，上訴第三審，並遭駁回。

（二）判決要旨

1. 按刑事訴訟法第376條所列各罪之案件，經第二審判決者，

不得上訴於第三審法院，為該法條所明定。本件上訴人吳○儀、丁○鈞、李○慧被訴妨害名譽，原審係依刑法第310條第2項論處罪刑，核屬刑事訴訟法第376條第1款之案件。依首開說明，既經第二審判決，自不得上訴於第三審法院。上訴人等猶提起上訴，顯為法所不許，應予駁回。

2. 至於上訴人等提出之「對中華民國（台灣）政府落實國際人權公約初次報告之審查國際獨立專家通過的結論性意見與建議」影本，其內容之第65點（上訴意旨誤載為第61點）雖記載「……被告第一審法院被判無罪，而在第二審法院被判有罪，就沒有上訴救濟的機會，這違反公政公約第14條第5項的規定。專家因此建議修訂刑事訴訟法第376條，讓每位第一審法院被判無罪，但第二審法院被判有罪之被告，都有權利上訴至第三審法院……」。然刑事訴訟法第376條係屬現行有效之法律，在未經修正前，職司審判之法院，自不得逕依上開「修訂刑事訴訟法第376條」之建議，即違反該法條之規定。
3. 另上訴人等雖主張：渠等均經第一審諭知無罪，而第二審改判渠等三人有罪，依刑事訴訟法第376條第1項之規定，不得上訴於第三審法院，「有違憲之虞」，請求本院裁定停止訴訟程序，聲請司法院解釋云云。惟司法院釋字第572號解釋，已揭示：「法官於審理案件時，對於應適用之法律，依其合理之確信，認為有牴觸憲法之疑義者，各級法院得以之為先決問題，裁定停止訴訟程序，並提出客觀上形成確信法律為違憲之具體理由，聲請大法官解釋，……。其中所謂『先決問題』，係指審理原因案件之法院，確信系爭法律違憲，顯然於該案件之裁判結果有影響者而言；所謂『提出客觀上形成確信法律為違憲之具體理由』，係指聲請法院應於聲請書內詳敘其對系爭違憲法律之闡釋，以及對據以審查之憲法規範意涵之說明，並基於以上見解，提出其確信系爭法

律違反該憲法規範之論證，且其論證客觀上無明顯錯誤者，始足當之。如僅對法律是否違憲發生疑義，或系爭法律有合憲解釋之可能者，尚難謂已提出客觀上形成確信法律為違憲之具體理由。」換言之，法院聲請釋憲時應「提出其確信系爭法律違反該憲法規範之論證，且其論證客觀上無明顯錯誤者，始足當之。如『僅對法律是否違憲發生疑義』，……尚難謂已提出客觀上形成確信法律為違憲之具體理由」。上訴人等雖以刑事訴訟法第376條第1款之規定「有違憲之虞」為由，促請本院向司法院聲請解釋。然所謂有違憲之虞，「僅係對法律是否違憲發生疑義」，並非謂對於「法律為違憲」，已達於合理之確信。而上開解釋已明示：「如僅對法律是否違憲發生疑義，尚難謂已提出客觀上形成確信法律為違憲之具體理由。」本件既欠缺「確信法律為違憲之具體理由」，徒泛言「有違憲之虞」，即顯與上開得裁定停止訴訟程序，聲請釋憲應具備之程式不相適合，併此敘明。

二、最高法院103年度台上字第216號刑事判決

（一）案例事實

最高法院103年度台上字第216號刑事判決⁹³（下稱【判決二】）之案例事實為：

蕭○蘊與顏○容同為台北市內湖區○○社區之住戶，兩人素有不睦。2010年11月18日晚上7時15分許，顏○容下班返回社區，在B棟1樓大廳與服務該社區之富邦物業秘書王○卿聊天並繳費時，適蕭○蘊在上開社區○棟○樓住處，透過住戶對講機與位於1樓大廳

93 歷審判決：臺灣士林地方法院101年度易字第412號刑事判決、臺灣高等法院102年度上易字第1221號刑事判決、最高法院103年度台上字第216號刑事判決（上訴駁回）。

櫃檯之王○卿對話，稱「我隔壁那個不知廉恥的東西，你們主任有沒有去處理」等語，因對講機擴音為顏○容在旁聽聞，顏○容回以「妳在罵誰不知廉恥的東西！」王○卿見狀，將對講機切斷。蕭○蔦旋搭電梯來到1樓大廳櫃檯旁，以「不知廉恥的東西！」等語辱罵○杏。

案經檢察官提起公訴，一審判決為無罪，檢察官不服一審判決，提起上訴，二審撤銷原判決，認定被告違反公然侮辱罪。被告蕭○蔦不服二審判決，上訴第三審，並遭駁回。蕭○蔦復不服第二審確定判決，聲請再審，再審聲請並遭裁定駁回。

（二）判決要旨

1. 按刑事訴訟法第376條所列各罪之案件，經第二審判決者，不得上訴於第三審法院，為該法條所明定。本件上訴人蕭○蔦被訴妨害名譽，原審係依刑法第309條第1項論處罪刑，核屬刑事訴訟法第376條第1款之案件。依首開說明，既經第二審判決，自不得上訴於第三審法院。上訴人猶提起上訴，顯為法所不許，應予駁回。
2. 至於上訴人援引聯合國人權事務委員會第32號一般性意見，及國際獨立專家所通過之「結論性意見與建議」，謂刑事訴訟法第376條對於第一審無罪，第二審改判有罪之案件，仍不准被告上訴，顯已侵犯被告依據公民與政治權利國際公約第14條第5項規定所享有的「聲請上一級法院覆判權」，而上開公約具有國內法律的效力，且效力高於與之相牴觸的國內法，是刑事訴訟法第376條與前開公約規定不符部分，應不再適用云云。然刑事訴訟法第376條係屬現行有效之法律，在未經修正前，職司審判之法院，自不得逕依上開「修訂刑事訴訟法第376條」之建議，即違反該法條之規定，併予敘明。

三、司法院釋字第752號解釋

（一）聲請事實及爭點

聲請人張○仁（下稱聲請人一）因竊盜案件，經第二審法院就第一審判決有罪部分均予維持，第一審判決無罪之部分犯行則改判有罪，並認其所犯之竊盜罪屬不得上訴於第三審法院而確定。聲請人一認刑事訴訟法第376條第2款有牴觸憲法第7條及第23條之疑義。聲請人陳○宏（下稱聲請人二）因違反性騷擾防治法案件，經第二審法院撤銷第一審無罪判決，改判有罪，並認其所犯之罪屬不得上訴於第三審法院而確定。聲請人二認刑事訴訟法第376條第1款有牴觸憲法第7條及第16條之疑義。

聲請人一、聲請人二分別就刑事訴訟法第376條第1款、第2款規定提出聲請。大法官認為上開二聲請人雖係分別就同條不同款規定提出聲請，然而，因刑事訴訟法第376條第1、2款是否牴觸憲法，有其共通性，於是併案審理。

而本次解釋爭點則係，刑事訴訟法第376條第1款及第2款所列案件：

1. 經第一審判決被告有罪，而第二審駁回上訴或撤銷原審判決並自為有罪判決，不得上訴於第三審法院，是否違憲？
2. 經第一審判決被告無罪，但第二審撤銷原審判決而自為有罪判決者，不得上訴於第三審法院，是否違憲？

（二）解釋文

刑事訴訟法第376條第1款及第2款規定：「下列各罪之案件，經第二審判決者，不得上訴於第三審法院：一、最重本刑為三年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪。二、刑法第320條、第321條之竊盜罪。」就經第一審判決有罪，而第二審駁回上訴或撤銷原審判決

並自為有罪判決者，規定不得上訴於第三審法院部分，屬立法形成範圍，與憲法第16條保障人民訴訟權之意旨尚無違背。惟就第二審撤銷原審無罪判決並自為有罪判決者，被告不得上訴於第三審法院部分，未能提供至少一次上訴救濟之機會，與憲法第16條保障人民訴訟權之意旨有違，應自本解釋公布之日起失其效力。

上開二款所列案件，經第二審撤銷原審無罪判決並自為有罪判決，於本解釋公布之日，尚未逾上訴期間者，被告及得為被告利益上訴之人得依法上訴。原第二審法院，應裁定曉示被告得於該裁定送達之翌日起10日內，向該法院提出第三審上訴之意旨。被告於本解釋公布前，已於前揭上訴期間內上訴而尚未裁判者，法院不得依刑事訴訟法第376條第1款及第2款規定駁回上訴。

（三）解釋理由書摘要

1. 人民初次受有罪判決，其人身、財產等權利亦可能因而遭受不利益。為有效保障人民訴訟權，避免錯誤或冤抑，依前開本院解釋意旨，至少應予一次上訴救濟之機會，亦屬訴訟權保障之核心內容。
2. 刑事訴訟法第376條（該條第1款及第2款下併稱系爭規定）係立法機關衡量訴訟案件之種類、性質、訴訟政策目的、訴訟制度之功能及司法資源之有效運用等因素，所為之裁量。倘就系爭規定所列案件，被告經第一審判決有罪，而第二審駁回上訴或撤銷原審判決並自為有罪判決，因其就第一審有罪之判決，已有由上訴審法院審判之機會，就此部分，系爭規定不許其提起第三審上訴，屬立法形成範圍，與憲法第16條保障人民訴訟權之意旨尚無違背。
3. 惟系爭規定就所列案件，經第二審撤銷原審無罪判決並自為有罪判決者，亦規定不得上訴於第三審法院，使被告於初次

受有罪判決後即告確定，無法以通常程序請求上訴審法院審查，以尋求救濟之機會。刑事訴訟法第420條以下所規定再審以及第441條以下所規定非常上訴等程序對經第二審撤銷原審無罪判決並自為有罪判決之被告，所可提供之救濟，均不足以替代以上訴之方式所為之通常救濟程序。系爭規定就經第二審撤銷原審無罪判決並改判有罪所應賦予之適當上訴機會，既屬訴訟權保障之核心內容，故非立法機關得以衡量各項因素，以裁量是否予以限制之審級設計問題。系爭規定所列案件，經第二審撤銷原審無罪判決並自為有罪判決者，初次受有罪判決之被告不得上訴於第三審法院之部分，未能提供至少一次上訴救濟之機會，以避免錯誤或冤抑，與憲法第16條保障人民訴訟權之意旨有違，應自本解釋公布之日起失其效力。

4. 系爭規定所列案件，經第二審撤銷原審無罪判決並自為有罪判決，於本解釋公布之日，尚未逾上訴期間者，被告及得為被告利益上訴之人得依法上訴。原第二審法院，應裁定曉示被告得於該裁定送達之翌日起10日內，向該法院提出第三審上訴之意旨。被告於本解釋公布前，已於前揭上訴期間內上訴而尚未裁判者，法院不得依系爭規定駁回上訴。
5. 聲請人一就本解釋之原因案件，曾於上訴期間內提起上訴，經第二審法院以確定終局裁定駁回，該程序裁定，不生實質確定力。該法院應依本解釋意旨，就該第二審撤銷原審無罪判決並自為有罪判決部分之上訴，逕送第三審法院妥適審判。
6. 聲請人二就本解釋之原因案件，得於本解釋送達之日起10日內，依本解釋意旨及刑事訴訟法上訴之相關規定，就第二審撤銷原審無罪判決並自為有罪判決之部分，上訴於第三審法院。

四、綜合評釋

自前揭兩則判決案例事實及判決要旨可知，【判決一】、【判決二】之各該被告被訴之行為分別是刑法加重誹謗以及公然侮辱罪嫌，亦同是一審無罪、二審改判有罪之情形，屬刑事訴訟法第376條微罪經第二審判決即不得上訴於第三審之案件。而最高法院就該等案件之上訴程序上予以駁回之理由也的確是本於刑事訴訟法第376條規定而來。

不過，如前所述，按業具國內法效力之公政公約第14條第5項依法覆判實質保障權利規定及人權事務委員會之相關解釋意見可知，覆判權利之保障並不限於重罪，且該權利保障必須使受有罪判決者能夠有效地向其上級法院提出上訴。而【判決一】、【判決二】這兩則案例即為人權事務委員會具體例示的公政公約第14條第5項規定之典型違反態樣，因此，本文以下即先就該兩則判決為比較分析並綜合評釋。

（一）國際專家之結論性意見屬兩公約施行法第3條所稱應參照之「解釋」

首先，【判決一】、【判決二】均提及之「不得逕依國際獨立專家對我國提出之結論性意見與建議『修訂刑事訴訟法第376條』之建議即認定違反該法條之規定」，此即為國際獨立專家結論性意見規範效力之問題。

因我國本身之特殊情況及於國際地位之困境等關係，無法直接透過人權事務委員會審查我國之定期報告（包含初次報告）進而作成結論性意見及建議，因此，我國於2013年首度繳交國家人權報告書，以「自辦」的方式，請具有審查經驗之國際人權專家來審查我國之國家報告，而該等國際獨立專家審查我國國家報告後即通過了所謂的「結論性意見及建議」。就此「結論性意見及建議」，或有拘

束力法源依據之爭論，亦即「結論性意見及建議」係依據公政公約第40條⁹⁴（國際法根源）抑或係兩公約施行法第6條（內國法效力）之論辯。

不過，不論是哪一種觀點，就結論言，仍是有效力。對此，本文認為，既兩公約施行法業具國內法效力，又兩公約施行法第6條更明文規定「政府應依兩公約規定，建立人權報告制度。」結合同法第2條內國法效力規定，則依此所建立之人權報告制度以及國際獨立專家審查我國國家報告後所通過之「結論性意見及建議」應具內國法拘束力；況且，我國自行邀請國際獨立專家至我國審查國家報告，實質上即已取代了人權事務委員會之結論性意見⁹⁵；事實上，自兩公約施行以來，也有不少法院裁判陸續適用該等國際獨立專家所通過之「結論性意見及建議」進而做出對被告有利之決定或藉此強化國內之既有規範⁹⁶。

因此，【判決一】、【判決二】於駁回之判決理由一開頭即認定「不得逕依國際獨立專家對我國提出之結論性意見與建議『修訂刑事訴訟法第376條』之建議即認定違反該法條之規定」此誠稍嫌武斷，且究其原因，應係其未熟悉公約解釋之故。另外，即便該等判決不引用國際獨立專家對我國提出之結論性意見與建議，自人權事

94 公政公約第40條：「一、本公約締約國承允依照下列規定，各就其實施本公約所確認權利而採取之措施，及在享受各種權利方面所獲之進展，提具報告書：（一）本公約對關係締約國生效後一年內；（二）其後遇委員會提出請求時。二、所有報告書應交由聯合國秘書長轉送委員會審議。如有任何因素及困難影響本公約之實施，報告書應予說明。三、聯合國秘書長與委員會商洽後得將報告書中屬於關係專門機關職權範圍之部分副本轉送各該專門機關。四、委員會應研究本公約締約國提出之報告書。委員會應向締約國提送其報告書及其認為適當之一般評議。委員會亦得將此等評議連同其自本公約締約國收到之報告書副本轉送經濟暨社會理事會。五、本公約締約國得就可能依據本條第四項規定提出之任何評議向委員會提出意見。」

95 廖福特（註50），頁939。

96 例見：最高法院102年度台上字第4289號刑事判決、最高法院104年度台上字第2268號刑事判決。

務委員會之相關解釋意見包含一般性意見、個人申訴決定意旨均可清楚得知公政公約第14條第5項依法覆判實質保障權利之保障並不限於重罪且「下級法院諭知無罪判決後，上訴判決改判有罪且按國內法不得上訴」屬典型的公約違反情形，更何況，如前所述，此權利受公約實質保障，並不容締約國按其國內法任意解釋。

（二）法官有義務適用具現行法效力之公政公約第14條第5項規定

其次，可以合理提出懷疑的是：不論是【判決一】或【判決二】似乎均未意識到內國司法部門受公約拘束乙事。

按人權事務委員會第31號一般性意見第15段意見：「委員會十分重視締約國設立適當的司法機制和行政機制，以便根據國內法來處理有關侵犯權利的指控。委員會注意到，司法部門可用許多不同的方式以有效保證人們享有《公約》所承認的權利。其中包括：直接執行《公約》、實施類似的憲法或者其他法律規定，或者在實施國內法時對《公約》做出解釋。⁹⁷」即人權事務委員會要求締約國司法部門必須直接適用公約規定，或直接適用與公約所保障權利相同或類似之內國憲法或法律規定，乃至於解釋適用國內法時將該等公約權利納入考量。

另一方面，實則，就公政公約對國內司法部門拘束力之論述，我國法院已有判決明確指出，遵守公政公約之於締約國，不論立法、行政、司法各部門均受有拘束，且締約國不得以國內法規定作為拒絕落實公約之理由⁹⁸。

97 Human Rights Committee, General Comment No. 31, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), para. 15.

98 例見：臺灣臺北地方法院103年度訴字第3489號民事判決：「公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法（下稱施行法）自98年12月10日施行以後，施行法第2條及第3條之規定使公政公約關於保障人權之規定具有國內法律之效力，適用時應參照其立法意旨及聯合國人權事務委員會（下稱人權事務委員會）之解釋。又人權事務委員會關於公政公約的義務對各締

此外，就兩公約之解釋除了依兩公約施行法第3條規定外，依據國內法院對國際條約之解釋除了依一致性解釋原則使國內法與條約意旨一致外，更應依據1969年維也納條約法公約第31條及第32條之條約解釋通則釐清條約規範內涵。雖然此項解釋通則未被兩公約施行法第3條所提及，但由於已具習慣國際法地位並受到國際性法庭、聯合國及其附屬機構、國際法實務及學界所廣為使用，故當我國國內法院審理涉及公約權利之案件時，為落實兩公約施行法第4條，並確保公約規範目的之實現，除該施行法第3條規定之解釋方法外，更應適用維也納條約法公約所揭示的解釋通則為之。實則，於我國最高法院若干判決⁹⁹中已有直接使用一致性解釋之實踐經驗，更具有間接呈現兩公約就與之不一致的國內法規定之優先適用效果之實例¹⁰⁰。

因此，法院於行使審判職權時，有義務（優先）適用具國內法效力之公政公約規定及其相關解釋意見。據此，不論是【判決一】或【判決二】，法官於適用刑事訴訟法第376條時，即應直接適用公政公約第14條第5項依法覆判實質保障權利規定，或直接在解釋適用刑事訴訟法第376條時將該等公約權利之實質保障內涵納入考量。

不過，於該等案件中，二審法院即高等法院及其分院係就個案改判有罪之審級，其就公政公約第14條第5項依法覆判實質保障權利規定究竟得以發揮如何程度之空間，也就是說，二審法院於這類案件中「能做些什麼」，誠值探究。蓋對於二審法院而言，公政公約第14條第5項之規定並非要求其於判決上的實質論罪科刑等判

約國受有拘束力一事，曾以第31號一般性意見（General Comment No. 34，編按：應為 No. 31）加以闡釋，認為各締約國的行政、立法、司法各部門均同受拘束（第31號一般性意見第4段、第34號一般性意見第7段參照）。且依維也納條約法公約（Vienna Convention on the Law of Treaties）第27條之規定，締約國不得以國內法之規定作為拒絕落實公約之理由。」

99 例見：最高法院101年度台上字第4028號刑事判決、最高法院101年度台上字第4531號刑事判決。

100 徐揮彥（註32），頁886。

斷，不過，因於裁判實務上，法院於判決書末段之欄位當中，除公訴檢察官姓名、判決之日期及法院、附錄論罪科刑法條等記載之外，通常會提示案件當事人「得否上訴、何人得上訴（例如無罪判決之情況，僅有檢察官得上訴）」等教示條款。因此，就該等一審法院判無罪後二審判決改判有罪且按刑事訴訟法第376條不得上訴之案件，二審法院本於公政公約第14條第5項依法覆判實質保障權利規定應可於口頭或判決書中提示當事人得按公政公約第14條第5項提起上訴，並且於當事人向其提起上訴時，協助將其上訴書狀轉由最高法院為後續審理。事實上，二審實務中，已有法院在個案判決書中透過上開教示條款之記載作出示範¹⁰¹，譬如臺灣高等法院105年度上易字第1156號刑事判決於判決書末段教示條款欄位中記載如下字眼，使當事人得以了解其得按公政公約第14條第5項提起上訴，實值肯定：

如不服本判決，應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後10日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。本件屬刑事訴訟法第三百七十六條第一款之罪，原不得上訴，惟因第一審判決無罪，本院改判有罪，依據公民與政治權利國際公約第十四條第五項：「經判定犯罪者，有權聲請上級法院依法覆判其有罪判決及所科刑罰」之規定，應屬例外得上訴第三審請求覆判之案件。

101 又如，於臺灣高等法院105年度上易字第2624號刑事判決中，亦有作類似的權利揭示即：「依刑事訴訟法第376條規定，本件黃麗寬所犯傷害罪原不得上訴第三審。但因為第一審判決她無罪，本院改判有罪，依據公民與政治權利國際公約第14條第5項：『經判定犯罪者，有權聲請上級法院依法覆判其有罪判決及所科刑罰』規定，她應有上訴請求覆判的權利。為符合公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法第2條規定的意旨，應例外准許黃麗寬得上訴第三審。是以，黃麗寬如不服本判決，應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀，她如未敘述上訴理由時，並得於提起上訴後10日內向本院補提理由書（須附繕本，以便提出給檢察官表示意見）『切勿逕送上級法院』」。

（三）最高法院應於程序上開庭辯論予以釐清

再者，最高法院曾於2012年10月30日的民、刑事庭庭長暨民、刑事法官司法事務分配小組聯席會議中決定從2012年12月起，「二審宣告死刑的案件」¹⁰²以及「具有法律上重要意義或價值的民、刑事案件」上訴三審時，一律行言詞辯論¹⁰³。事實上，自2012年12月迄今，最高法院開庭審理之案件，除二審宣告死刑案件之外，也包含許多具有法律上重要意義或價值的民刑事案件¹⁰⁴。

¹⁰² 於我國司法裁判實務之脈絡上，死刑案件係討論公政公約適用及論述的重要觀察對象。蓋以我國最高法院刑事判決為例，自兩公約施行迄今，死刑案件的确是適用公政公約的最大宗案件類型，究其原因，此除係彰顯司法對於生命權之尊重以及最高法院確實也就此類案件持續性地召開言詞辯論庭而有更多機會讓檢辯雙方做「生死辯」進而呈現於法院判決書之外，另外一個重要理由是，公政公約第6條規定所建立的死刑裁判人權基準和我國既有刑事法制（諸如刑法第57條量刑條款、刑法第19條責任能力）確實有所落差及若干解釋空間，而此等落差及解釋空間對於裁判實務向來處理死刑案件的面相也有了不小改變。進言之，最高法院於其近年來的判決當中，透過兩公約此一基礎，已逐漸發展諸如公政公約第6條第2項「情節最重大之罪」、相關解釋中「精障判死禁止」準則的建立、死刑判決的程序保障（連結公政公約第14條）等人權基準，因此，以最高法院就死刑案件之言詞辯論及兩公約適用經驗作為相對論述之對象，不論是就公約規定適用本身或司法實踐實然面的觀察均具相當程度之重要性。參見廖福特（註50），頁950-952；林慈偉，從公民與政治權利國際公約論死刑裁判之人權基準——最高法院近年相關裁判之綜合評析，軍法專刊，61卷4期，頁167-168（2015年）。

¹⁰³ 最高法院關於言詞辯論新聞稿，最高法院，<http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=28337>（最後瀏覽日：2021年11月1日）。嗣最高法院更於2016年5月31日105年度第9次刑事庭會議通過「最高法院刑事案件行言詞辯論要點」，該要點第1點規定「行言詞辯論之案件：（一）案件涉重要法律爭議，合議庭認為有必要者，應行言詞辯論。（二）原審宣告死刑之案件，除判決明顯違背法令，必須撤銷發回外，應行言詞辯論。」

¹⁰⁴ 例見：最高法院104年度上字第1341號臺北市府地政局與高千惠等間請求國家賠償上訴事件（2016年7月29日行言詞辯論）、最高法院104年度上字第707號秀岡山莊第一期社區管理委員會等與吳啟孝律師（即秀岡開發事業股份有限公司之破產管理人）等間請求所有權移轉登記等上訴事件（2016年6月21日行言詞辯論）、最高法院104年度上字第1092號朱明德違反銀行法等罪檢察官上訴案件（2016年6月1日行言詞辯論、2016年4月14日行準備程序）等等，均係因具法律上重要意義或價值的民、刑事案件而於最高法院開庭行言詞辯論（或準備程序）。

不論是【判決一】或【判決二】，一個重要的程序爭點即係對於刑事訴訟法第376條微罪上訴限制規定與公政公約第14條第5項依法覆判實質保障權利規定間的解釋適用問題。特別是於【判決一】中，上訴人尚提出促請法院停止訴訟程序聲請釋憲等主張，而該等主張不正突顯出本件實為具法律上重要意義或價值的刑事案件！不過，最高法院未能就此等爭點開庭探究，而逕以駁回，誠然可惜。

另外，雖非該二則判決理由獨有，但從中亦可發現的一個現象是，於該兩則判決中，甚少對相關公約條款所規定之權利內涵進行釐清與詮釋，且所謂涉及公約權利之主張也都是上訴人單純地依國內法律規定主張後附帶提出以突顯該權利被侵害之情狀，很可惜的是，於該等判決中甚少可以見到釐清該權利內涵及國家對此權利應實踐之義務內涵，遑論將此涵攝於本案系爭事實及相關國內法法律關係進而提出完整主張，此現象對於人民在公約所保障權利之實現上或法院判決的公約實踐上均可能造成減損之效果，實不可不慎。

不過，就「一審判無罪、二審改判有罪且上訴人按公政公約第14條第5項上訴最高法院」之案件，最高法院究竟要如何於其個案中適用公政公約第14條第5項規定，換句話說，最高法院於這類案件中「應做些什麼」。

對此，本文認為，因公政公約第14條第5項於系爭案件之程序意義實益乃彰顯於程序救濟、覆判權利此一面向，是以，最高法院可先確認個案與公政公約第14條第5項具關聯性，再就人權事務委員會對該權利之詮釋內涵、與國內既有規範之落差於其判決中為說明及論證。倘若最高法院於現階段未能了解刑事訴訟法第376條微罪上訴限制規定與公政公約第14條第5項依法覆判實質保障權利規定間的解釋適用問題，則於此情形應可認此個案爭點具法律上重要意義進而應開啟言詞辯論，甚至也可以於個案中邀請專家對此表示專業意見。反之，倘若最高法院認為上訴人於該等案件中按公政公

約第14條第5項規定提起上訴係屬無疑義者，則除非其承審個案尚有他法律重要意義或因他事由而有開庭之必要外，當可逕自實質審理¹⁰⁵。事實上，最高法院若據此為實質審理，亦非困難之事，蓋於我國刑事三級三審結構下，其他不受刑事訴訟法第376條上訴限制之「非微罪案件」本即存有「一審判無罪二審改判有罪而上訴三審」之情形及案例經驗，因此，最高法院據此審理，對其審判實務乃至於執行面向上亦應無障礙或困難之處。

（四）司法院釋字第752號解釋之評釋及其後續效應¹⁰⁶

1. 錯失良機：未適時透過國際人權公約強化其解釋意旨

2017年7月28日，大法官就「刑事訴訟法第376條第1款及第2款所列案件：1、經第一審判決被告有罪，而第二審駁回上訴或撤銷原審判決並自為有罪判決，不得上訴於第三審法院，是否違憲？2、經第一審判決被告無罪，但第二審撤銷原審判決而自為有罪判決者，不得上訴於第三審法院，是否違憲？」作成司法院釋字第752號解釋（下稱「釋字752」），明確宣告刑事訴訟法第376條第1款及第2款規定就經第一審判決有罪，而第二審駁回上訴或撤銷原審判決並自為有罪判決者，規定不得上訴於第三審法院部分，屬立法形成範圍，與憲法第16條保障人民訴訟權之意旨尚無違背，但「就第二審撤銷原審無罪判決並自為有罪判決者，被告不得上訴於第三

¹⁰⁵ 或許有認為，若最高法院據此為審理，是否將生混淆法律審、事實審上訴等疑義？對此，本文認為，因公政公約第14條第5項規定所稱上訴（appeal）或覆判（review）應係為實質理解，此等理解並不受內國法概念的限制，換言之，不論是事實審上訴抑或係法律審上訴皆屬之，此自前揭一般性意見亦可得知，公政公約對此權利內涵之重點在於內國法於此等情形必須提供通常救濟的機會，且以具一定品質要求之審級救濟為必要。

¹⁰⁶ 司法院釋字第752號解釋係就刑事訴訟法第376條第1、2款相關部分為解釋，此等解釋內容與本文所提出之刑事上訴三審限制疑義直接相關，據此，以下基於本文整體架構即繼續從公政公約第14條第5項規定、公約適用觀點出發，就司法院釋字第752號解釋及其該號解釋之後續效應，特別是普通法院於該號解釋後就相關案件應如何進行審判程序及因應等為析論。

審法院部分，未能提供至少一次上訴救濟之機會，與憲法第16條保障人民訴訟權之意旨有違，應自本解釋公布之日起失其效力。」於此似就本文所提出及研析之刑事上訴三審限制疑義，及從憲法第16條訴訟權保障角度作出一階段性的裁斷。

進一步言，釋字752多數意見主要係立基於憲法第16條保障人民訴訟權以及「有權利即有救濟」之憲法原則論證得出，刑事訴訟法第376條第1款及第2款規定就第二審撤銷原審無罪判決並自為有罪判決者使被告不得上訴於第三審法院部分而未能提供至少一次上訴救濟之機會，與憲法第16條保障人民訴訟權之意旨有違之結論。但從該號解釋文及解釋理由書以觀，與本號解釋爭點直接相關、同時也是本文所關注之重點規範即公政公約第14條第5項依法覆判實質保障權利卻似乎不為多數意見所重視。

對此，黃昭元大法官在意見書的「註4」中說明本號解釋未正式參考引用公政公約第14條第5項規定及人權事務委員會一般性意見之緣由¹⁰⁷：

公民與政治權利國際公約第14條第5項規定：「經判犯罪者，有權聲請上級法院依覆判其有罪決及所科刑罰。」與本號解釋爭點有關。按上述公約雖已經國內法化，但其形式上仍只是國會法律位階的規範，並無法成為聲請或解釋憲法的權利依據。其次，上述公約規定之文義範圍係泛指任何有罪判決都應有上訴機會，這和本號解釋之限於「一審無罪、二審有罪」的情形，顯然有別。即使參考公約委員會第32號一般性意見（General Comment No. 32）的第47點，其所期待締約國保障上訴權的案件類型（包括終審法院撤銷下級審無罪判決而自為有罪判決等情形），亦明顯超

107 司法院釋字第752號解釋黃昭元大法官部分協同、部分不同意見書。

過本號解釋所審理及承認的範圍。為免引發不必要爭議，因此本號解釋沒有正式參考、引用上述公約及其委員會之一般性意見，而是直接闡釋憲法訴訟權應保障之核心內容。

就多數意見未同意納入公約之此項規定，以強化解釋意旨，羅昌發大法官於意見書中表示此誠屬可惜¹⁰⁸：

本院雖無法直接「適用」國際人權公約之規定作為憲法解釋之依據，然本院在解釋憲法時，實應參照公約內容，經由解釋之過程將公約之精神融入憲法條文，以適當賦予憲法第16條與時俱進且符合國際標準之內涵。參照前揭公約規定「由一個較高級法庭進行審查」之結果，自亦應作成如本號解釋之內容。多數意見未同意納入公約之此項規定，以強化本解釋之意旨，甚為可惜。

就大法官是否以及如何引用、參考國際人權公約於相關司法院大法官解釋當中，固然有其不同意見；又如前所述，本號解釋文及理由書就與本號解釋爭點相關之公政公約第14條第5項規定亦隻字未提。然而，從個別大法官之意見書以觀，其等大多認同本號解釋意旨乃與公政公約第14條第5項規定相呼應、旨趣相同。譬如，林俊益大法官在意見書中即表示本號解釋確立被告初次受有罪判決至少應有一次上訴救濟機會此一憲法原則乃與公政公約第14條第5項之規範意旨相符¹⁰⁹：

本席秉持著每件大法官解釋應比以往的解釋更為進步的信念，協力完成本解釋，從我國諸多有關訴訟保障意旨之解釋先例中，進一步創新憲法保障訴訟權的核心內容，確立【被告初次受有罪判決至少應有一次上訴救濟機會】的憲法

108 司法院釋字第752號解釋羅昌發大法官協同意見書。

109 司法院釋字第752號解釋林俊益大法官部分協同意見書。

原則，與公民權利與政治權利國際公約（International Covenant on Civil and Political Rights）第14條第5項之規範意旨相符，再度邁向憲法人權保障的新里程，殊值贊嘆與肯定！

又如，黃虹霞大法官在意見書中也表示本號解釋雖因多數意見未達共識而未能直接引用公政公約作為解釋依據或參考，但解釋意旨已與之相呼應¹¹⁰：

聯合國公民與政治權利國際公約第14條第5項規定：「經判定犯罪者，有權聲請上級法院依法覆判其有罪判決及所科刑罰。」本件解釋雖因未達共識而未能直接引之為解釋依據或參考，但本件解釋意旨已與之相呼應，亦可認為係釋憲上之進步。

再如，許志雄大法官在意見書中也認同本號解釋基於訴訟權之積極內容使初次受有罪判決之人至少應予一次上訴救濟之機會與公政公約第14條第5項旨趣相同¹¹¹：

公民與政治權利國際公約第14條第5項規定：「經判定犯罪者，有權聲請上級法院依法覆判其有罪判決及所科刑罰。」本號解釋基於訴訟權之積極內容，認為人民初次受有罪判決者，至少應予一次上訴救濟之機會，旨趣相同，本席深表認同。

事實上，就國際人權公約之於憲法解釋之可能關聯，於我國學界已有若干討論。諸如：國際人權公約於我國之地位及效力、國際人權公約是我國憲法解釋的規範依據抑或係參考資料、各別國際人權公約之權利是否有憲法層級規範等等。

110 司法院釋字第752號解釋黃虹霞大法官協同意見書。

111 司法院釋字第752號解釋許志雄大法官協同意見書。

譬如有論者自國際人權公約與憲法解釋的匯流觀點認為，「國際法的憲法化」及「憲法的國際化」已成為全球規範秩序的主流，其並呼籲職司釋憲之責的大法官，應該要主動面對此一趨勢，強化自身對於國際人權法的認知，並以國際人權法的相關司法機制與社群為對話對象，積極將兩公約及核心國際人權公約定位為憲法法源，與憲法既有的人權清單，共同作為保障人權的規範基礎¹¹²。

亦有認為，在面對國際化的潮流，形式上似乎蘊含了「究竟要服從國際人權規範？還是要堅守本國憲法基本權規範？」這樣的擇一關係以及思考盲點，其自德國法秩序的發展經驗以及兩公約在我國的實踐脈絡觀察進而指出，若欲釐清國際及區域人權公約在我國憲法解釋中應該扮演的角色，則必須清楚區隔不同的人權公約對我國憲法基本權不同的功能定位，讓應該成為解釋與具體化依據的國際人權公約確實發揮引導並形塑我國憲法基本權規範內涵的作用，也讓作為單純解釋參考對象的絕大多數國際及區域人權公約，可以回歸到比較法脈絡之下，提供憲法解釋過程中參酌比較的資源¹¹³。

若以公政公約為例，有論者認為公政公約的權利位階可更細緻地分為不同的層次，供大法官於憲法解釋時適用或參考，質言之，公政公約中有些規定本身的保障程度低於我國現行法，不應優先適用，有些規定因時代變遷，如今已嫌保守，有待檢討，有些規定涉及困難的憲法權利衝突問題，仍應由大法官透過憲法解釋予以釐清，或審查其相關立法的合憲性¹¹⁴。

112 張文貞，國際人權公約與憲法解釋：匯流的模式、功能及台灣實踐，司法院大法官104年度學術研討會，司法院主辦，頁3、26（2015年12月5日）。

113 黃舒芃，國際及區域人權公約在憲法解釋中扮演的角色：兼評司法院釋憲實務對國際及區域人權公約之看待與引用方式，司法院大法官104年度學術研討會，司法院主辦，頁64-65（2015年12月5日）。

114 就具體之權利層次位階，其更進一步認為公政公約的權利位階可分為三個層次：（1）其中具有絕對法性質者，可直接適用並為解釋依據；（2）非我國憲法已明文規定的公約權利，且具有相當於憲法權利之重要性者，得承認為非明文憲法權利；（3）其他公約權利得為大法官於解釋既有憲法權利時之參

本文初步認為，有關聯合國各國國際人權公約之人權規定之於大法官解釋之關係為何，以及各國國際人權公約規定是否為解釋憲法之依據，此等問題，固然有其複雜性，惟有鑑於聯合國各該國際人權公約本身及其所作之相關權威解釋意見，乃與時俱進，合乎時宜之國際人權基準，是縱使不認同該等國際人權公約有條約等效力，其亦可作為大法官解釋我國憲法相關條文時之參考依據，透過比較法解釋的方式，填充相關之憲法規範內容。特別是在釋字752所處理之爭點係相對單純且明確與公政公約第14條第5項規定直接相關之情況下，本號解釋未能適時透過國際人權公約以強化其解釋意旨，甚或透過憲法解釋來調和各別公約權利與我國憲法間的可能不一致，錯失此一呈現公政公約與憲法解釋間可能關聯之良機，誠然可惜。

事實上，公政公約第14條第5項實質覆判權利保障之於刑事訴訟法第376條刑事上訴三審限制規定，應如何調和？是否應予引入以及如何引入？例如立法者應如何設計相關刑事程序？以及在立法未完備前，普通法院究應如何適用公政公約第14條第5項規定？實務爭議不斷，此等疑義應該也是最需要大法官表示意見之所在。

2. 未竟之業：未就刑事訴訟法第376條第3至7款一併審查

本號解釋除了錯失說明公政公約與憲法解釋的可能關聯之外，另外一個問題點是，就本號解釋之「審查客體」而言，多數意見因囿於聲請人等之原因案件所適用法條，僅就刑事訴訟法第376條第1、2款規定為審查，而未能一併就與同條第1、2款密切相關之第3至7款為審查¹¹⁵。對此未一併審查刑事訴訟法第376條第3至7款之決

考。參見黃昭元，公民與政治權利國際公約與憲法解釋，司法院大法官104年度學術研討會，司法院主辦，頁123（2015年12月5日）。

¹¹⁵ 刑事訴訟法第376條：「下列各罪之案件，經第二審判決者，不得上訴於第三審法院：一、最重本刑為三年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪。二、刑法第三百二十條、第三百二十一條之竊盜罪。三、刑法第三百三十五條、第

定，若干大法官於個別的意見書中，均花了不少篇幅提出質疑聲浪。

(1) 若干大法官意見書所發出的質疑聲浪

釋字752之所以未將刑事訴訟法第376條第3至7款一併審查之原因，應係慮及不告不理原則等考量¹¹⁶。不過，本號解釋多數意見因受限大法官釋憲的「程序要件」而未能將刑事訴訟法第376條第3至7款一併納入審查，此隨即引發了不少位大法官於各別意見書中以相當之篇幅提出強烈批判¹¹⁷。就結論而言，該等批判意見，大多認為刑事訴訟法第376條第3至7款亦應納入本號解釋之審查客體，惟其等所持理由並不完全相同。

例如，羅昌發大法官基於規範整體評價以及「法律解釋應避免荒謬結果」原則，於其意見書中表示¹¹⁸：

本件情形，如不將刑事訴訟法第376條第3款至第7款納為解釋客體，將使各該款所列案件之被告，於本解釋公布後，且在立法機關尚未依本解釋意旨修改第376條規定前，仍不得就第二審法院由第一審無罪判決改判有罪者，上訴於第

三百三十六條第二項之侵占罪。四、刑法第三百三十九條、第三百四十一條之詐欺罪。五、刑法第三百四十二條之背信罪。六、刑法第三百四十六條之恐嚇罪。七、刑法第三百四十九條第一項之贓物罪。」

116 司法院釋字第752號解釋林俊益大法官部分協同意見書：「由於本件聲請人二人所涉原因案件，僅涉及系爭規定，而不及於終局裁定裁判所未適用之刑事訴訟法第376條第3款至第7款，基於司法不告不理被動原則，本解釋多數意見爰僅就系爭規定部分宣告違憲，而不及其他第3款至第7款之規定。」（粗體為作者所強調）、司法院釋字第752號解釋黃昭元大法官部分協同、部分不同意見書：「刑事訴訟法第376條第3至7款的類似限制：受限於不告不理原則，本號解釋只審查有提出聲請之刑事訴訟法第376條第1款及第2款規定，並宣告上述規定部分合憲、部分違憲。」（粗體為作者所強調）

117 對本號解釋限縮審查客體範圍以相當篇幅提出批評者共計有：司法院釋字第752號解釋羅昌發大法官、黃虹霞大法官、黃瑞明大法官、詹森林大法官等協同意見書。

118 司法院釋字第752號解釋羅昌發大法官協同意見書。

三審法院。其結果，本解釋反而造成第376條所列案件中，同因第二審法院由無罪改判有罪者，第1款與第2款所列案件之被告得上訴於第三審法院，第3款至第7款所列案件之被告則不得上訴於第三審法院之差別待遇。如此之解釋，不但無法真正闡明本院對刑事訴訟法第376條整體之憲法評價，以維護憲政秩序目的，反而因本院解釋造成明顯差別待遇之荒謬結果。本席認為，依前揭「法律解釋應避免荒謬結果」之相同意旨，自應將該條第3款至第7款納入解釋，一併處理，始為適當。(粗體為作者強調)。

又如，黃虹霞大法官則認為本號解釋未將刑事訴訟法第376條第3款至第7款併納入解釋範圍，乃未充分考量法體系完整且與平等原則不符¹¹⁹：

限制第三審上訴是刑事訴訟法第376條本文之規定，而依本解釋所新確立之訴訟權核心內容（請見前壹），則刑事訴訟法第376條各款案件應均同適用，始合於法體系之完整性；而且因本解釋未將第3款至第7款一併納入，已致生在立法院完成該刑事訴訟法第376條修正前，第1款、第2款案件（在本件解釋之解釋文第1段後段範圍內者）可上訴第三審，而第3款至第7款案件則否之不合理差別，自亦與平等原則有違。(粗體為作者強調)。

再如，黃瑞明大法官認為本號解釋應將刑事訴訟法第376條第3至7款一併納入審查範圍，以貫徹釋憲意旨，且同條第3至第7款犯罪類型之被告經第二審撤銷原審無罪判決並為有罪判決者，無法依本號解釋提起上訴，此恐有違平等原則¹²⁰：

119 司法院釋字第752號解釋黃虹霞大法官協同意見書。

120 司法院釋字第752號解釋黃瑞明大法官協同意見書。

本號解釋之二位聲請人依其原因案件所適用法條，分別聲請解釋刑事訴訟法第376條第1款及第2款是否抵觸憲法。本號解釋亦僅宣告此二款失其效力，故同條第3款至第7款之規定並不在本號解釋之解釋範圍內。然而刑事訴訟法第376條第2款至第7款之規定均有其共同點，即均為暴力成份比較不強之侵害財產法益之犯罪類型，且立法院於立法時，就第1款至第7款列入不得上訴第三審之案件類型，均係以減輕法官之工作負擔為理由，就此而言，第3款至第7款案件類型與本件聲請標的（第1款及第2款）關聯密切，應可一併納入審查範圍，以貫徹釋憲意旨（司法院釋字第569號解釋理由書參照），故本號解釋並未對第3款至第7款同時為違憲之宣告，美中不足。第3款至第7款犯罪類型之被告經第二審撤銷原審無罪判決並為有罪判決者，無法依本號解釋提起上訴，恐亦有違平等原則。（粗體為作者強調）。

另外，詹森林大法官更是認為，本號解釋放棄一併審查刑事訴訟法第376條第3款至第7款規定乃自行限縮本解釋效力範圍，此不符體系正義，亦製造人民負擔¹²¹：

本條第3款至第7款規定亦為侵害訴訟權保障之核心內容；惟本解釋卻未一併宣告該第3款至第7款規定在此範圍內違憲，導致限縮本解釋之效力範圍，殊屬遺憾……本條7款規定，均基於相同之立法緣由（上訴第三審之刑事案件日增，法官不勝負荷），並追求相同之立法目的（減輕第三審法院之負擔，使其集中精力處理較為重大繁雜之案件），且均屬限制人民訴訟權之核心內容；其中第2款至第7款所定之犯罪，更是性質相同（皆為侵害財產法益）、刑度接近（最重本刑均為5年有期徒刑）。因此，在體系正義要求下，

121 司法院釋字第752號解釋詹森林大法官協同意見書。

本條全部7款規定，均應等同處理；第2款至第7款規定，更不得不同看待……更有甚者，由於本解釋在此部分之沈默，可預料者為，本解釋公布後……保守或固執之法官，就第3款至第7款規定之情形，必然依舊拒絕被告之第三審上訴，遭拒絕之被告僅得再次聲請本院解釋。本席大膽預言，就此類之解釋憲法聲請，本院應不至於作成有異於本解釋意旨之不同解釋。因此，除非立法者本於本解釋意旨，儘速修正本條規定，並修改為本條全部7款規定之案件，於第一審判決無罪，而第二審改判有罪時，為被告之利益，一律得上訴於第三審法院；否則，人民仍須一再奔波於出庭應訴、聲請解釋、提起再審，不僅製造人民無謂負擔，且與刑事訴訟法第376條所欲達成之「減輕法官負擔」背道而馳。（粗體為作者強調）。

（2）本號解釋擴張審理刑事訴訟法第376條第3款至第7款規定之可能性

回到釋字752，再進一步探知該號解釋之所以未一併審查刑事訴訟法第376條第3款至第7款規定，其原因實係涉及人民得以聲請釋憲以及大法官得以審理之標的範圍等訴訟類型與要件解釋適用問題¹²²。

蓋按司法院大法官審理案件法（下稱「大審法」）第5條第1項第2款規定¹²³，人民聲請釋憲之標的為「確定終局裁判所適用之法

122 蓋就相關案件之是否以及如何程度被大法官所受理，此於憲法訴訟即大法官釋憲的「程序」上，當有諸如「列舉原則」及憲法訴訟類型（聲請解釋類型）上的思考，而此等程序之遵循亦係確保大法官於合法的程序內行使其權限以達憲法最高性得以維護以及人民權利保障的實現，參見吳信華，憲法訴訟——「訴訟類型」：第一講——「憲法訴訟」與「訴訟類型」的基本概念，月旦法學教室，66期，頁37-41、43（2008年）。

123 司法院大法官審理案件法第5條第1項第2款：「有左列情形之一者，得聲請解釋憲法：……人民、法人或政黨於其憲法上所保障之權利，遭受不法侵害，經依法定程序提起訴訟，對於確定終局裁判所適用之法律或命令發生有牴觸

律或命令」，就此，解釋上應係指「確定終局裁判上以之為裁判依據的法律或命令」，因此，釋字752多數意見認為，二位釋憲聲請人之確定終局裁判分別係就刑事訴訟法第376條第2款（聲請人一）以及第1款（聲請人二）為「適用」，因此大法官也僅就該第1、2款（排除第3至7款）作為審理標的。

不過，於憲法訴訟學理上，大法官依此限定其審理標的是否即無任何疑問，此容有討論之空間。

蓋自司法院釋字第445號解釋開始，大法官即曾有以「基於客觀憲政秩序之維護」及「相關聯且必要」理由作為擴張受理案件聲請對象之見解¹²⁴：

惟人民聲請憲法解釋之制度，除為保障當事人之基本權利外，亦有闡明憲法真義以維護憲政秩序之目的，故其解釋範圍自得及於該具體事件相關聯且必要之法條內容有無牴觸憲法情事而為審理……足以說明大法官解釋憲法之範圍，不全以聲請意旨所述者為限。（粗體為作者強調）。

甚者，後來司法院釋字第535號解釋，更明確地採取了「重要關聯性」見解，作為擴張個案確定終局裁判「所適用」法律或命令之範圍解釋¹²⁵：

所謂裁判所適用之法律或命令，係指法令之違憲與否與該裁判有重要關聯性而言。以刑事判決為例，並不限於判決中據以論罪科刑之實體法及訴訟法之規定，包括作為判斷行為違法性依據之法令在內，均得為聲請釋憲之對象。（粗體為作者強調）。

憲法之疑義者。……」

124 司法院釋字第445號解釋理由書。司法院釋字第737、747號解釋亦同意旨。

125 司法院釋字第535號解釋理由書。

於司法院釋字第535號解釋之後，大法官亦於若干個案中以類似「重要關聯性」的說明作為擴張受理對象的依據，諸如司法院釋字第569、576、580號解釋均是¹²⁶。換言之，從以往的相關大法官解釋經驗觀之，於人民聲請釋憲的相關案例中，大法官就審查之範圍並不絕對侷限於確定終局裁判「形式上」以之為裁判依據的法律或命令¹²⁷。

然而，對於大法官以「重要關聯性」或類似用語作為擴張審理之理由，文獻上有認為，大法官或已將所謂「相關聯」，乃至於「重要關聯性」視為一個可擴張審理的既定法則，但卻從未對之真正有合理內容的說明或完整的類型化，且適用上的標準亦不一致¹²⁸。

本文基本上同此意見並進而認為，雖大法官屢以「重要關聯性」作為擴張審理範圍之理由，惟何謂「重要關聯性」，至今並無統一的判斷標準¹²⁹，此概念實不明確，亦引發標準不一之疑慮。不過，這不代表本文全然否定大法官擴張審理範圍的任何空間，蓋仍可想像大法官基於諸如公益目的、客觀憲法秩序的維護等原因，而有擴張審理標的之必要，此誠如論者所言，在基於「客觀目的」而擴張審理的脈絡下，若大法官認為某條文雖非終局裁判所適用之法

126 司法院釋字第569號解釋理由書：「上開解釋雖非本件聲請解釋之標的，惟與系爭判例關聯密切，為貫徹釋憲意旨，應一併納入審查範圍」；司法院釋字第576號解釋理由書：「依司法院大法官審理案件法第五條第一項第二款規定聲請本院解釋憲法時，本院審查之對象，非僅以聲請書明指者為限，且包含該確定終局裁判援引為裁判基礎之法令，並與聲請人聲請釋憲之法令具有重要關聯者在內。」司法院釋字第580號解釋理由書：「有重要關聯，應一併納入解釋範圍」。

127 甚至，除「重要關聯性」之外，大法官亦有以「實質援用」概念作為擴張審理範圍之例，例如司法院釋字第582號解釋即是。

128 吳信華，大法官規範審查程序中「擴張審理標的」之研究——以「重要關聯性」的探究為中心，東吳法律學報，24卷4期，頁49（2013年）。

129 許玉秀前大法官即曾於司法院釋字第580號解釋中的一部協同暨一部不同意見書中舉司法院釋字第558、535、445號等解釋說明大法官歷來所提出之「重要關聯性」概念並無統一的判斷標準。

令但認為有相同的構成要件及違憲理由而欲一併審理的情形之下，此時大法官得本於「同一部法律之中基於同樣理由而違憲」之客觀理由為擴張審理，不宜再以本身即為不明確的「重要關聯性」概念作為說理¹³⁰。

據此，本文認為，釋字752多數意見固然有不告不理等考量，也理解大法官解釋權之司法性及被動性，但於大法官釋憲之程序上，實不必然要完全侷限於聲請人等之確定終局裁判所適用法令而自我限縮審理範圍，蓋不論是依照過去大法官釋憲程序中已屢次以「重要關聯性」等理由以擴張其審理標的¹³¹，抑或係本文所認為比較適宜的方法即基於「同一部法律之中同樣理由而違憲」之客觀理由擴張審理，這些都是大法官得持為擴張審理標的之可能理由¹³²。

具體而言，以釋字752為例，於此應可考量的是，刑事訴訟法第376條第3至7款與同條第1、2款既然列於同一條，且係存在相同之規範目的而具密切關聯性，甚至第3至7款之於第1、2款也可能基於相同理由而違憲，此際若仍侷限於聲請人之聲請客體不予以審理，則第3至7款日後尚需待其他聲請人（人民或法官）再聲請時方能處理，則此與事理亦恐有未合，在架構客觀合憲秩序之思考下，基於法安定性與實質妥當性乃至於訴訟經濟等考量，大法官於此亦應就第3至7款予以一併審理。

本文要再特別強調的是，就聲請人之聲請標的以及大法官之審查標的，其並非全然禁止大法官於釋憲案例中擴張審查範圍，因為於個案中亦確有其擴張之必要性，不過，重點仍是，擴張標準的統

130 吳信華（註128），頁46。

131 司法院釋字第752號解釋林俊益、羅昌發、黃瑞明、詹森林大法官協同意見書中均有提及以「重要關聯性」作為擴張大法官於本案審理標的範圍之可行性。

132 不過，不論是基於何種理由及概念而欲「擴張審理範圍」，相較於透過大法官解釋造法，較為周延的方法應當還是通盤檢討司法院大法官審理案件法相關程序要件及規定。

一及依此建構合理的類型與解釋範圍¹³³。且誠如論者所言，對於司法院大法官而言，能否發展出界定解釋標的之精確判準，與其能否扮演好憲法解釋機關的角色密切相關，允宜更加留意¹³⁴。

不過，很可惜地，釋字752不論於解釋文或理由書中就不予以審理刑事訴訟法第376條第3至7款規定均無任何說明，因此也無法得知該號解釋曾否審酌過「重要關聯性」等更為具體的理由。退一步言，姑且不論「重要關聯性」之確切內涵與相關問題，若持先前諸多大法官解釋案例標準以觀，釋字752多數意見未循「重要關聯性」此一擴張審查範圍之途，一併處理刑事訴訟法第376條第3至7款規定，亦當有思辯空間。

據此，可以預見的是，因刑事訴訟法第376條第3至7款規定，未一併為該號解釋所審理，此於未來司法實務上，若發生個案屬於刑事訴訟法第376條第3至7款規定罪名之案件且確實也發生了二審撤銷原審無罪判決並自為有罪判決時，則該等個案被告得否上訴第三審法院，此又是另一個未解決的大難題，該號解釋未能一併處理同條法律中同樣理由違憲的範疇，將造成未來司法實務更大的適用疑義，此實為釋字752的未竟之業。

3. 後續效應：司法院釋字第752號解釋之後，普通法院要怎麼做？

承前所述，釋字752看似已階段性地處理了刑事上訴三審限制之疑義，但其實不然，因為大法官沒有說現行刑事訴訟法第376條第1、2款本身違憲，而是「當刑事訴訟法第376條第1、2款的案件

¹³³ 於此當應注意以聲請解釋之類型（人民聲請釋憲或法官聲請釋憲）決定憲法解釋標的之判準等思考點。就此詳見，陳愛娥，司法院大法官憲法解釋之標的——以聲請外解釋的認定困難為中心，台灣本土法學雜誌，59期，頁112-114（2004年）。

¹³⁴ 陳愛娥（註133），頁119。

發生二審撤銷原審無罪判決、改判有罪，不得上訴三審」這件事違憲，除此之外，大法官並沒有一併處理刑事訴訟法第376條第3至7款之部分。因此，上文「伍、四」處所提出之疑義以及關於公約適用等問題，未來普通法院特別是三審法院及二審法院依釋字752為案件之審理時，所面臨之問題及可參酌之情狀，仍幾為同一，甚至更為複雜。

換言之，釋字752未處理之刑事訴訟法第376條第3至7款所涉案件，並不因該號解釋而有所受益，因此，嚴格論之，這類案件除了無得以按釋字752上訴之空間外，更不用說，這類案件本即存有之按公政公約規定主張相關權利的討論及適用疑義，並不因該號解釋之出爐而有所解決；至於有關刑事訴訟法第376條第1、2款規定所涉案件經二審撤銷原審無罪判決並自為有罪判決者，此部分雖業經釋字752作出違憲之結論而使相關案件得以按該號解釋上訴救濟，但同樣地，這類案件仍然存有依公政公約規定主張相關權利及公約解釋適用之疑義。

至於釋字752之後，對於未來相關刑事審判案件及程序勢必將產生影響，特別是該號解釋之溯及既往及適用效力，那麼普通法院，特別是高等法院（及其分院）和最高法院，於該號解釋後應該要怎麼做？

就此，釋字752理由書明確表示准許若干通案得以溯及救濟：

系爭規定所列案件，經第二審撤銷原審無罪判決並自為有罪判決，於本解釋公布之日，尚未逾上訴期間（包括在途期間）者，被告及得為被告利益上訴之人（刑事訴訟法第344條第4項、第345條及第346條參照）得依法上訴。原第二審法院，應裁定曉示被告得於該裁定送達之翌日起10日內，向該法院提出第三審上訴之意旨。被告於本解釋公布

前，已於前揭上訴期間內上訴而尚未裁判者，法院不得依系爭規定駁回上訴。

據此可知，對於二審法院即高等法院及其分院而言，因釋字752准許若干通案得以溯及救濟的關係，亦即原則上該號解釋自公布日（2017年7月28日）起向將來發生效力，但因該號解釋明確揭示若干通案的溯及生效，分別就「如未上訴者，得依法上訴；如已上訴而尚未裁判者」，法院不得依刑事訴訟法第376條第1款及第2款規定駁回上訴，據此，高等法院及其分院應遵循該號解釋意旨以落實保障被告之訴訟權益，就其院內受理案件中凡符合該號解釋所列情形，也就是經撤銷一審無罪判決並自為有罪判決之案件，自該解釋公布之日，尚未逾上訴期間，或於該解釋公布前，已於上訴期間內上訴而尚未裁判者，予以清查。就清查結果所得件數，裁定曉示分別通知各該被告及得為被告利益上訴之人，得依法上訴之旨。嗣並將依法上訴之該等案件併送至最高法院審理¹³⁵。

對於最高法院而言，相關案件若確按釋字752意旨合法上訴至最高法院者，則最高法院當依法予以審理¹³⁶。

135 有關基於司法院釋字第752號解釋而得以溯及之若干通案救濟射程範圍以及實質確定力等問題，可參見司法院釋字第752號解釋林俊益大法官協同意見書中之具體例示及說明。

136 至於依司法院釋字第752號解釋上訴第三審如經發回更審判決有罪能否再提起上訴此一疑問，因該號解釋多數意見並未再進一步說明，惟黃瑞明大法官於其意見書中表示：「本號解釋文指出刑事訴訟法第376條第1款及第2款規定『未能提供至少一次上訴救濟之機會，與憲法第16條保障人民訴訟權之意旨有違』，解釋理由亦指出『至少應予一次上訴救濟之機會，亦屬訴訟權保障之核心內容』。然而本號解釋在適用上仍可能有如下之疑義：依本號解釋上訴於第三審之案件，如經第三審撤銷原審判決而發回更審，更審判決有罪，被告能否依本號解釋再行上訴？解釋上有二種可能性：1、因本號解釋是保障『至少一次上訴救濟之機會』，被告經上訴後若經更審判決有罪，即已滿足『至少一次上訴救濟之機會』之要求，應回歸刑事訴訟法第376條之規定，經二審有罪判決確定，不得上訴於第三審。2、因為發回更審後，原審之有罪判決業經被撤銷不存在，故回復一審無罪、二審有罪之情形，依本號解釋意旨仍應得上訴第三審，第三審駁回上訴始告確定。以上二種解釋可能性究採何者，應於

不過，就釋字752多數意見允許溯及效力擴張至若干通案救濟，有少數大法官持反對意見。例如，黃昭元大法官認為，多數意見未充分說明理由即擴張該號解釋之溯及效力，恐有恣意之嫌¹³⁷：

然解釋文第2段在未充分說明理由下，逕將溯及效力擴張及於「非聲請人、也未曾提出聲請」，且原已確定的相關類似案件，以致形成「未聲請，卻有救濟」的特殊待遇。又以本號解釋公布日之「前10日內」（即於2017年7月18至27日間）送達二審有罪判決之案件為溯及範圍，其時間點之選擇，亦使有無溯及效力之適用，受到與法理無關的事務性偶然因素（如製作判決書、郵務效率等）之更多影響，恐有恣意之嫌。

又如黃璽君大法官更是認為，從釋憲解釋效力原則上係向將來生效，僅於原因個案例外發生溯及效力，多數意見論知溯及適用於已確定之判決，與大法官解釋先例相違，嚴重破壞法安定性¹³⁸：

在顯然欠缺公益理由下，本解釋使本院解釋之效力一概溯及適用於「系爭規定所列案件，於本解釋公布之日，尚未逾上訴期間」者與本院一貫見解相違，嚴重破壞法安定性，實非妥適。又上訴期間屆滿前提起上訴尚未裁判者，甚或已獲有罪判決而尚未執行者，按多數意見之論理，何以未能享有溯及之利益？亦待商榷。

至於釋字752之二原因案件後續應如何進行其救濟，釋字752解釋理由書也已明確指引聲請人一、聲請人二各別之具體救濟方法：

未來立法時明確規定以杜爭議。」參見司法院釋字第752號解釋黃瑞明大法官協同意見書。

137 司法院釋字第752號解釋黃昭元大法官部分協同部分不同意見書。

138 司法院釋字第752號解釋黃璽君大法官部分不同意見書。

聲請人一就本解釋之原因案件，曾於上訴期間內提起上訴，經第二審法院以確定終局裁定駁回，該程序裁定，不生實質確定力。該法院應依本解釋意旨，就該第二審撤銷原審無罪判決並自為有罪判決部分之上訴，逕送第三審法院妥適審判。聲請人二就本解釋之原因案件，得於本解釋送達之日起10日內，依本解釋意旨及刑事訴訟法上訴之相關規定，就第二審撤銷原審無罪判決並自為有罪判決之部分，上訴於第三審法院。

五、小結

（一）痼疾未去又添新病：公約適用疑義加上大法官解釋之未竟之業

釋字752就公政公約第14條第5項隻字未提（圖1之C），此實錯失釐清公政公約規定與憲法解釋間可能關聯之良機；又該號解釋僅認定刑事訴訟法第376條第1、2款不得上訴三審規定，就第二審撤銷原審無罪判決自行改判有罪不得上訴三審之此部分宣告違憲（圖1之a），而未能就同條第3至7款作一併之審理（圖1之B），亦屬未竟之業。

從【判決一】【判決二】的案例分析可知，刑事上訴三審限制此一議題，於我國司法實務操作上，本即有未能精確釐清公約適用等疑義，如今，再加上釋字752的未竟之業，可謂「痼疾未去又添新病」。

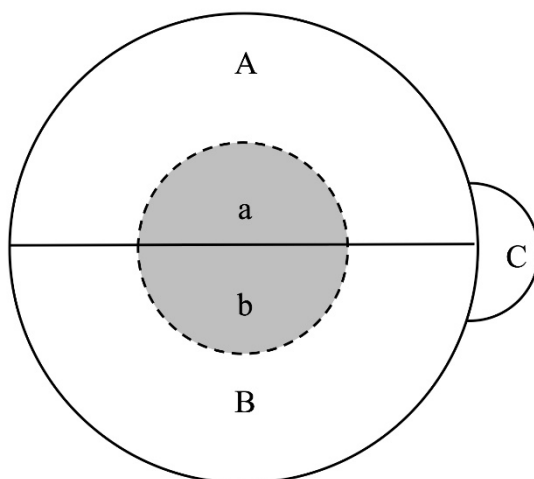


圖1 刑事訴訟法第376條各款、司法院釋字第752號解釋之
審理標的、公政公約第14條第5項之適用對應圖示

資料來源：作者製圖。

說明：A（含a，下同）+B（含b，下同）=刑事訴訟法第376條各款

A=刑事訴訟法第376條第1、2款

B=刑事訴訟法第376條第3至7款

a+b=第二審撤銷原審無罪判決自行改判有罪

a=因司法院釋字第752號解釋而失其效力之範圍

C=公政公約第14條第5項

在痼疾添新病的雙管齊下，不難預見此對於未來司法實務將產生更多的適用疑義。

譬如，在大法官釋憲的層面上，詹森林大法官於意見書中即直言刑事訴訟法第376條第3至7款於未來實務上勢必再度發生是否違憲之爭議：「更有甚者，由於本解釋在此部分之沈默，可預料者為，本解釋公布後，就第3款至第7款規定，勢必再度發生是否違憲之爭議，導致立法者原本相同評價之本條全部7款規定，實務上，

第1、2款規定與第3至7款規定，卻有完全不同之評價。而且，保守或固執之法官，就第3款至第7款規定之情形，必然依舊拒絕被告之第三審上訴，遭拒絕之被告僅得再次聲請本院解釋。¹³⁹」

又如，對於普通法院而言，也可能產生如下疑義：就二審撤銷原審無罪判決並自為有罪判決者之非屬刑事訴訟法第376條第1至2款案件（圖1之b）之被告而言，得否按釋字752意旨上訴三審？若個案被告依該號解釋對二審法院提出第三審上訴意旨，二審法院得否本於該號解釋意旨送三審法院審理？又或者，若個案被告非依該號解釋，而係持公政公約第14條第5項規定對二審法院提出第三審上訴之意旨，則二審法院得否本於公約規定將案件送三審法院審理？三審法院應否或以如何之法依據受理該等案件？若二審法院移送三審法院後，三審法院就此等規範之適用疑義於程序上是否應開庭予以釐清？於釋字752後，刑事訴訟法第376條各款涉及二審撤銷原審無罪判決並自為有罪判決之案件，與該號解釋，乃至於公政公約第14條第5項間的適用關係為何？此等疑義均有待釐清¹⁴⁰。

值得一提的是，在釋字752公布（2017年7月28日）、立法院三讀通過新修正刑事訴訟法第376條（2017年11月7日）之後，最高法

139 司法院釋字第752號解釋詹森林大法官協同意見書。

140 本文認為，於立法尚未確按釋字752意旨修正前之個案處理上，司法應適當地透過解釋的方式釐清、緩和相關適用疑義。例如，大法官若遇有符合刑事訴訟法第376條第3至7款任一款規定且拒絕被告上訴三審之釋憲聲請，則應當一併就該條各款項全盤解釋處理。另一方面，因釋字752僅處理刑事訴訟法第376條第1款、第2款之部分，卻沒有處理同條第3至7款，此顯不符平等原則，因此，普通法院就刑事訴訟法第376條第3款至第7款類似案件之審理時，亦應一併考量釋字752解釋意旨，比照辦理，允許各該個案被告得按釋字752提起上訴。至於業具國內法效力之公政公約第14條第5項依法覆判實質保障權利規定，本即係當事人得於具體個案中執為救濟、上訴之依據，且同前文所述，此部分並不因釋字752而有所影響，換言之，二審法院本於公政公約第14條第5項依法覆判實質保障權利規定，同樣地，應可於口頭或判決書中提示當事人得按公政公約第14條第5項規定提起上訴。為符「有權利必有救濟」之憲法原則及公約意旨，三審法院亦應本於公政公約第14條第5項規定及合乎公約之內國法解釋，容許該等案件上訴三審救濟。

院以106年度第17次刑事庭會議決定（2017年11月14日）充分展現了其緩和適用疑義之作用，亦即就「刑事訴訟法第376條第3款至第7款所列案件，經第一審判決被告無罪，但第二審撤銷原審判決並自為有罪判決者，於釋字752公布日起提起第三審上訴或上訴中尚未審結者，第二審法院依本法第384條前段裁定駁回第三審上訴者，如何補救？」作出決定，其內容如下¹⁴¹：

系爭上訴與釋字第752號解釋所指之本法第376條第1款、第2款之上訴，有其共通性，應一體適用該號解釋（該號解釋因基於不告不理原則，祇就第1、2款為解釋）。故本院就系爭上訴，均暫時不審結，俟同法第3款至第7款修正條文施行後（已於106年11月7日經立法院三讀通過），依新法所定為得提起第三審上訴之規定為審理。茲系爭上訴如第二審法院逕行裁定上訴駁回，與之相較，實違反平等原則。似可參照釋字第752號解釋文第二段末「被告於本解釋公布前，已於前揭上訴期間內上訴而尚未裁判者，法院不得依刑事訴訟法第376條第1款及第2款規定駁回上訴。」及解釋理由書末段「聲請人一就本解釋之原因案件，曾於上訴期間內提起上訴，經第二審法院以確定終局裁定駁回，該程序裁定，不生實質確定力。該法院應依本解釋意旨，就該第二審撤銷原審無罪判決並自為有罪判決部分之上訴，逕送第三審法院妥適審判」之旨，認該第二審駁回上訴之裁定，不生實質確定力（參照司法院釋字第271號解釋、本院80年11月5日80年度第5次刑事庭會議決議、本院25年上字第3231號判例，認利於被告之上訴，如誤合法為不合法而判決駁回上訴者，該判決不生實質確定力。亦為相同之見

¹⁴¹ 參見最高法院106年度第17次刑事庭會議決定新聞稿，司法院，<http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/NNWSS002.asp?id=296682&flag=1®i=1&key=752&MuchInfo=&courtid=>（最後瀏覽日：2021年11月1日）。

解)。故如由原審法院將該案件移送本院審理，自應予受理。俾與未經第二審法院裁定駁回之系爭上訴為相同之處理。

(二) 正確診斷才能正確開藥方：刑事訴訟法第376條之修法檢討

關於上訴三審限制規制及其適用疑義，本文認為，釜底抽薪之道，應當還是要回歸其背後所牽涉之立法政策考量，特別是在第三審已採嚴格法律審應可大幅減少第三審上訴案件數量之情況下，釐清整體刑事案件類型負擔現況，進而修法整體檢討。就刑事立法及政策之觀點言，本文初步認為，上訴三審限制之規範應悉以「上訴理由」為準，而非逕以「案件類型或罪刑之輕重」作為不得上訴之門檻，此一方面透過上訴理由之有效控制使第三審案件負荷上有所緩和，另方面也可維持第三審作為嚴格法律審、發揮統一解釋法令之功能。

退一步言，即便僅從公政公約第14條第5項保障內涵的觀點而言，縱為刑事訴訟法第376條各款之罪，被告於一審獲判無罪後，若檢方上訴第二審，卻經第二審改判有罪時，即告確定，並無上訴救濟之機會，此顯已侵害人民訴訟權利，故為保障人民訴訟之權利，縱為輕罪，亦不得完全剝奪被告遭判決有罪後得以上訴之機會，如此方符公政公約第14條第5項保障內涵以及釋字752意旨。

所幸，於釋字752公布後，立法院即迅速地三讀通過（2017年11月7日）並經總統公布了新修正刑事訴訟法第376條（2017年11月16日）：

下列各罪之案件，經第二審判決者，不得上訴於第三審法院。但第一審法院所為無罪、免訴、不受理或管轄錯誤之判決，經第二審法院撤銷並諭知有罪之判決者，被告或得為被告利益上訴之人得提起上訴：一、最重本刑為三年以

下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪。二、刑法第三百二十條、第三百二十一條之竊盜罪。三、刑法第三百三十五條、第三百三十六條第二項之侵占罪。四、刑法第三百三十九條、第三百四十一條之詐欺罪。五、刑法第三百四十二條之背信罪。六、刑法第三百四十六條之恐嚇罪。七、刑法第三百四十九條第一項之贓物罪。(第1項)

依前項但書規定上訴，經第三審法院撤銷並發回原審法院判決者，不得上訴於第三審法院。(第2項)

本文認為，新修正刑事訴訟法第376條第1項但書規定之增訂，明確使被告得以在第二審初次受有罪判決時可以提起第三審上訴以資救濟，符合公政公約第14條第5項保障內涵以及司法院釋字752意旨，乃屬正確。第2項則是正面處理了釋字752所留下的「上訴第三審如經發回更審判決有罪能否再提起上訴」此一疑問，並採取被告經上訴後若經更審判決有罪即已滿足「至少一次上訴救濟之機會」之要求而應回歸刑事訴訟法第376條之規定，經二審有罪判決確定，不得上訴於第三審之立場。不過，可惜的是，新修正第1項仍漏未考量本文前所提出之應從刑事立法、政策之觀點出發，釐清我國現整體刑事案件類型負擔情況，找出真正案件負荷所在，而非鋸箭式地逕以「罪刑」作為限制種類基準。即便承認以「罪刑」作為上訴三審限制之標準，亦應檢視各該罪刑之程度，特別在我國刑法之竊盜罪、侵占罪、詐欺罪、背信罪、恐嚇罪及贓物罪等，其最重本刑均為5年以下有期徒刑，顯非輕罪之情況下，對其上訴第三審之案件嚴加限制，亦應一併檢討¹⁴²。

¹⁴² 於司法院釋字第752號解釋出爐後，有文獻隨即從司法院釋字第752號解釋對應於刑事訴訟法修正規定提出一致性以及未解問題之相關質疑與檢視，誠值參考。參見李榮耕，簡評釋字第752號解釋及刑事訴訟法的相關修正，月旦法學教室，181期，頁52-56（2017年）。

此外，就2017年新修正刑事訴訟法第376條公布生效之前的案件未能一體適用，也產生了新的問題。蓋如上所述，2017年11月16日雖修正公布刑事訴訟法，然而，該此修正規範生效之前的案件，仍適用舊法第376條的規定而不得上訴第三審。或有認為，此乃基於案件量負擔以及法不溯及既往等考量。不過，就案件數量的部分，按照我國第三次兩公約審查，由民間提出的平行報告所展現的數據是，一審無罪、二審改判有罪不得上訴之案件，一年約有三至四百件，而按最高法院現就刑事案件結案量及法官數量而言，最高法院現應有能力消化此類案件才是¹⁴³。而就法不溯及既往之部分，一方面，該次修法若採溯及既往，此乃有利於人民之溯及既往，另一方面，實則，若就溯及後所產生的法不安定有所疑慮者，立法上亦可設定特定之過渡期間（例如二年內），使得新修正刑事訴訟法第376條施行前第一審法院所為無罪經第二審法院撤銷並諭知有罪之判決，被告或得為被告利益上訴之人，於過渡期間內，可向法院聲請重新審理，以資救濟。此等配套作法，一方面可以兼顧溯及既往、法安定性等考量，另一方面，也得以避免因全然性地拒絕類似案件重新審判而蒙受冤錯之疑慮¹⁴⁴，事實上，2017年新修正刑事訴訟法第

¹⁴³ 「2017年11月16日修正公布《刑事訴訟法》第376條：『不得上訴第三審之案件，如於第一審獲判無罪、免訴、不受理或管轄錯誤之判決，而經第二審法院撤銷並諭知有罪之判決者，均得上訴第三審。』然而，該條規範卻自2017年11月18日始生效，亦即在2017年11月17日以前的案件，仍適用舊法第376條的規定，不得上訴第三審。根據司法院統計，這類型的案件，一年約300到400件，但最高法院一年審理的刑事案件結案量已從2007年的9,177件下降至2019年的6,637件，且最高法院法官人數仍舊維持在70人左右，顯然最高法院有能力負擔這類型的案件。」參見人權公約施行監督聯盟，2020兩公約平行報告，頁103，https://covenantwatch.org.tw/wp-content/uploads/2015/12/CW_2020-parallel-report-on-ICCPR-and-ICESCR_online_CH_REV.2.pdf（最後瀏覽日：2021年11月1日）。

¹⁴⁴ 修法前判決確定的案件仍然無法按2017年新修正刑事訴訟法第376條規定提起救濟之經典案例如【黃慧夫案】。該案為臺大整型外科醫師黃慧夫於2008年任職亞東醫院時，替病患截肢而被控業務過失重傷害，後來經一審判無罪、二審改判4月徒刑，受限當時刑事訴訟法第376條規定最重本刑為3年以下有期徒刑之輕罪不得上訴三審，因此該案於二審有罪定讞（2014年10月）。雖然後來

376條規定未能一體適用過去案件所可能產生的「冤錯黑數」，這恐怕也與釋字752將刑事訴訟制度中的「冤罪防抑」機制詮釋為我國人民受憲法第16條訴訟權保障的「核心領域」等意旨有為違背¹⁴⁵。

就此般新問題之產生，本文認為，若從公政公約第14條第5項而論，可以有兩點評論。第一，依本文之主張，不論修正前後之刑事訴訟法第376條，只要是一審獲判無罪但二審改判有罪者，此類案件本即可按公政公約第14條第5項規定解釋為得上訴三審救濟，換言之，法官於適用刑事訴訟法第376條時即應直接適用公政公約第14條第5項依法覆判實質保障權利規定，或直接在解釋適用刑事訴訟法第376條時將該等公約權利之實質保障內涵納入考量，因此，從這個角度反觀新修正刑事訴訟法第376條規定，僅因為施行生效時點而解釋為只適用於後來的案件，不適用修法前就定讞的類似案件，顧此失彼，這也再次證明了該次修法未意識到上訴覆審權利本即為刑事被告依循公政公約第14條第5項規定而有之權利保障。第二，因為2017年新修正刑事訴訟法第376條規定，顯然是為了遵循釋字752之意旨而修，所以再回過頭看，若釋字752能夠在其解釋中，適時地透過國際人權公約以強化其解釋意旨，甚或解釋調和公政公約第14條第5項覆判權利與憲法乃至於刑事訴訟法第376條之間的不一致，那麼2017年就刑事訴訟法第376條規定的該次修法，或許即能讓立法機關更全面性地關照到公政公約與憲法解釋間之連結以及立法實踐的更細緻化。

司法院釋字第752號解釋宣告刑事訴訟法第376條在一審無罪，二審有罪的情況下，限制上訴到第三審是違憲應立即失效，而立法院也因此修了刑事訴訟法第376條規定，但該次修正僅受惠於修法後的案件方得以適用上訴三審規定，像黃慧夫這樣在即修法前就確定的案件仍然無法救濟，所幸，該案嗣經提出相關鑑定證據作為新事證而於2018年成功開啟再審並於2019年12月19日獲判無罪。參見，黃慧夫案，民間司法改革基金會，<https://www.jrf.org.tw/keywords/87>（最後瀏覽日：2021年11月1日）。

¹⁴⁵ 蘇凱平，居於憲法訴訟權核心的冤罪防抑——評釋字第752號解釋，月旦裁判時報，66期，頁88（2017年）。

甚者，就此一新問題，也引發我國最新一次兩公約國際審查（即兩公約第三次國家報告國際審查）中委員會的質疑。亦即，根據我國兩公約第三次國家報告國際審查中公政公約與經社文公約國際審查委員會於2021年6月28日所提交之問題清單第28點，委員會即正面向我國政府提問：「根據審查委員會就《公政公約》第14(5)條受到違反而提出的建議，《刑事訴訟法》第376條於2017年11月16日修訂，自2017年11月18日起生效，允許一審獲判無罪但二審有罪判決者得向三審上訴。然而，根據《人權公約施行監督聯盟平行報告》第422點，該權利尚未提供給「2017年11月17日以前的案件」，此類案件仍然適用舊法。請政府說明為何沒有在所有未決案件中給予上訴權，以及這種限制如何符合公約第14(5)條。¹⁴⁶」（粗體為作者強調）。由此看來，公政公約第14條第5項規定覆判權利之本土立法及司法實踐的問題，此一公約權利之戰，並未因2017年刑事訴訟法第376條規定之修正而停歇。

陸、結論

我國刑事訴訟所定程序，刑事案件原則上以三審終結，不過，

¹⁴⁶ 原文為：“Following recommendations by the Review Committee to remedy a violation of Article 14 (5) ICCPR, Article 376 of the Code of Criminal Procedure was amended on 16 November 2017, with effect from 18 November 2017, in order to allow persons who have been acquitted in the first instance but convicted by the second instance to appeal to the third instance. However, according to the Parallel Report of Covenants Watch, § 422, the right has not been made available ‘to cases before November 17th, 2017’ which still follow the previous provisions. The Government is requested to explain why the right to appeal has not been granted in all pending cases and how such a limitation can be considered compatible with Article 14 (5).” 參見2021年6月28日《公民與政治權利國際公約》與《經濟社會文化權利國際公約》臺灣國際審查問題清單，法務部，<https://www.humanrights.moj.gov.tw/17725/17733/17735/17740/17742/>（最後瀏覽日：2021年11月1日）。

部分案件之第三審上訴則受案件類型的特別限制而不得上訴，刑事訴訟法第376條規定即是。刑事訴訟法第376條原為限制輕微案件不得上訴第三審之規定，於1995年修正時，為了減輕第三審法院之負荷，再度擴大不得上訴第三審法院案件之範圍。此等修正雖均係為達到減輕第三審案件負荷之目的，但當時卻也引發了諸如二審法院將無限制擴權、檢察官依職權不起訴範圍將因而擴大、冤錯判等偏消極面向的質疑，相較於此，就刑事訴訟法第376條上訴案件限制規定以及1995年擴大適用範圍之修法，學界則大多從憲法平等原則、訴訟權保障及刑事上訴審目的等論點直接對規定本身提出積極面向的檢討及批評。然而，即便有上開疑慮及檢討聲浪，但直至釋字752出爐之前，立法者於過去這段時間似乎也沒有任何修法進展或改善作為。

不過，隨著2009年兩人權公約於我國施行生效後，與刑事程序密切關聯之公政公約，對應於我國既有的刑事規制，就刑事訴訟法第376條規定及上揭疑慮作重新檢視，似乎是個可能的契機。特別是公政公約第14條第5項明文規定「經判定犯罪者，有權聲請上級法院依法覆判其有罪判決及所科刑罰。」即刑事覆判權利保障。而刑事覆判權利保障作為公政公約公平審判架構下的一環，人權事務委員會相關解釋對此權利保障更具體之闡釋，例如，刑事案件之有罪判決者必須能夠有效向每層級提出上訴、覆判權利之保障並不限於重罪、條文中所謂「依法」一詞並非旨在將覆判的根本權利交由締約國任意決定等均是。此外，人權事務委員會亦明確指出「一審法院判決即終審判決」、「下級法院諭知無罪判決後，上訴判決改判有罪且按國內法不得上訴」均屬違反公政公約第14條第5項之典型案例。對應於我國刑事訴訟法第376條排除「微罪」案件覆判權利之規定，個案即可能發生從一審無罪到二審改判有罪而不得上訴三審之情形，此正是人權事務委員會明確指出違反公政公約第14條第5項規定之具體示例。

既然刑事訴訟法第376條以及公政公約第14條第5項兩者同為「現行法」，那麼我國裁判實務於具體個案中是採取如何的立場及意見，即屬重要。從本文所示二則最高法院刑事裁判可知，其等尚不熟稔公約規定與內國刑事規制之連結及適用問題，例如，法官不解國際專家之結論性意見乃兩公約施行法第3條所稱應參照之「解釋」。而法官應依職權適用公約自無須待當事人主張而可直接適用公政公約依法覆判實質保障權利規定，另判決在解釋適用刑事訴訟法第376條時即應將該等公約權利納入考量並注意其間之論證義務等。

此外，釋字752基於訴訟權核心內容保障明確揭示人民初次受有罪判決時至少應予一次上訴救濟之機會，立意良善。不過，其就公政公約第14條第5項隻字未提，實錯失釐清公政公約規定與憲法解釋間可能關聯之良機，又該號解釋僅認定刑事訴訟法第376條第1、2款不得上訴三審規定，就第二審撤銷原審無罪判決自行改判有罪不得上訴三審之此部分宣告違憲，而未能就同條第3至7款作一併之審理，亦屬未竟之業。刑事上訴三審限制此一議題，於我國司法實務操作上，本即有未能精確釐清公約適用等疑義，如今再加上釋字752所遺留之未竟之業，可謂係痼疾未去又添新病，此不難預見將對於司法實務再產生更多適用上的問題。本文認為，關於上訴三審限制規制及其適用疑義，釜底抽薪之道，應當還是要回歸其背後所牽涉之立法政策考量進而修法整體檢討，在修法尚未完備之前，普通法院則應適當地透過解釋的方式予以釐清或緩和。

於釋字752公布後，2017年11月立法院三讀通過並經總統公布新修正刑事訴訟法第376條，該次修正使被告得以在第二審初次受有罪判決時可以提起第三審上訴以資救濟，符合公政公約第14條第5項保障內涵以及釋字752意旨，此部分之修正乃屬正確。不過，可惜的是，新修正規定仍漏未考量本文前述自刑事立法、政策觀點釐清我國現整體刑事案件類型負擔情況，找出真正案件負荷所在，而非鋸箭式地逕以「罪刑」作為限制種類基準；又即便接受以「罪

刑」作為上訴三審限制之標準，亦應檢視各該罪刑之程度，特別在我國刑法之竊盜罪、侵占罪、詐欺罪、背信罪、恐嚇罪及贓物罪等，其最重本刑均為5年以下有期徒刑，顯非輕罪之情況下，對其上訴第三審予以嚴加限制，亦有所不妥；此外，2017年新修正刑事訴訟法第376條公布生效之前的案件未能一體適用救濟所產生之此一冤錯黑數，使得公政公約第14條第5項規定覆判權利之本土立法、司法實踐問題，仍未獲全面解決。故期盼未來還有修法機會，能將刑事上訴三審限制規定進行全盤、合理且具正當性之修正。

**【附表】 刑事訴訟法第376條之修法條文及
修法理由對照**

立法沿革	條文	理由
(1967/01/13 全文修正)	刑法第六十一條所列各罪之案件經第二審判決者，不得上訴於第三審法院。	
(1995/10/05 修正)	左列各罪之案件，經第二審判決者，不得上訴於第三審法院： 一、最重本刑為三年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪。 二、刑法第三百二十條、第三百二十一條之竊盜罪。 三、刑法第三百三十五條、第三百三十六條第二項之侵占罪。 四、刑法第三百三十九條、第三百四十一條之詐欺罪。 五、刑法第三百四十二條之背信罪。 六、刑法第三百四十六條之恐嚇罪。 七、刑法第三百四十九條第二項之贓物罪。	上訴第三審之刑事案件日增，法官不勝負荷，參照外國對上訴第三審之案件均嚴加限制之立法例，關於第三百二十一條加重竊盜罪、第三百三十六條第二項業務侵占罪、第三百四十一條之準詐欺罪、第三百四十二條背信罪及第三百四十六條恐嚇取財罪等案件，修正為不得上訴於第三審法院。
(2014/12/09 修正)	下列各罪之案件，經第二審判決者，不得上訴於第三審法院： 一、最重本刑為三年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪。	一、刑法於一百零三年六月十八日修正，原第三百四十九條第一項：「收受贓物者，處三年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。」、第二項：「搬運、

	二、刑法第三百二十條、第三百二十一條之竊盜罪。 三、刑法第三百三十五條、第三百三十六條第二項之侵占罪。 四、刑法第三百三十九條、第三百四十一條之詐欺罪。 五、刑法第三百四十二條之背信罪。 六、刑法第三百四十六條之恐嚇罪。 七、刑法第三百四十九條第一項之贓物罪。	寄藏、故買贓物或為牙保者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。」，修正為第一項：「收受、搬運、寄藏、故買贓物或媒介者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬以下罰金。」。本條原條文第七款所指「刑法第三百四十九條第二項之贓物罪」，業因上開修正移列至第一項（其中僅「牙保」一語，另以同義之「媒介」代之），故有配合修正之必要。 二、修正前刑法第三百四十九條第一項收受贓物罪，原屬本條第一款所規定最重本刑為三年以下有期徒刑之罪，不得上訴於第三審法院，修正後雖法定刑提高為有期徒刑五年以下，惟同條項併列之搬運、寄藏、故買、媒介贓物罪，與之同屬侵害個人財產法益之罪，法定刑亦相同，且均不得上訴於第三審法院，基於體系上衡平性之考量，修正後之收受贓物罪案件，自亦不得上訴於第三審法院。爰修正原條文第七款之文字。 三、原條文第一項序文文字「左列」修正為「下列」，
--	--	---

		以符合現行法規用語。 四、原條文第一款至第六款均未修正。
(2017/11/7 修正)	下列各罪之案件，經第二審判決者，不得上訴於第三審法院。但第一審法院所為無罪、免訴、不受理或管轄錯誤之判決，經第二審法院撤銷並諭知有罪之判決者，被告或得為被告利益上訴之人得提起上訴： 一、最重本刑為三年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪。 二、刑法第三百二十條、第三百二十一條之竊盜罪。 三、刑法第三百三十五條、第三百三十六條第二項之侵占罪。 四、刑法第三百三十九條、第三百四十一條之詐欺罪。 五、刑法第三百四十二條之背信罪。 六、刑法第三百四十六條之恐嚇罪。 七、刑法第三百四十九條第一項之贓物罪。 依前項但書規定上訴，經第三審法院撤銷並發回原審法院判決者，不得上訴於第三審法院。	一、原條文限制特定範圍法定本刑或犯罪類型之案件，經第二審法院判決者，不得上訴第三審。惟上開案件經第二審法院撤銷第一審法院所為無罪、免訴、不受理或管轄錯誤判決，並諭知有罪判決（含科刑判決及免刑判決）者，因不得上訴第三審法院之結果，使被告於初次受有罪判決後即告確定，而無法依通常程序請求上訴審法院審查，以尋求救濟之機會，與憲法第十六條保障人民訴訟權之意旨有違（司法院釋字第七五二號解釋意旨參照）。為有效保障人民訴訟權，避免錯誤或冤抑，應予被告或得為被告利益上訴之人至少一次上訴救濟之機會，爰於本條序文增訂但書之規定。又第二審法院所為有罪判決，該案仍屬第二審判決，第三審法院審判就上訴案件之審理，自仍應適用第三審程序，乃屬當然。 二、第一項但書規定已賦予被告或得為被告利益上訴之

		人就初次有罪判決上訴救濟之機會，已足以有效保障人民訴訟權，為兼顧第三審法院合理之案件負荷，以發揮原有法律審之功能，依第一項但書規定上訴，經第三審法院撤銷並發回原審法院判決者，不得就第二審法院所為更審判決，上訴於第三審法院，爰增訂第二項規定。
--	--	---

參考文獻

1. 中文部分

- Helmut Satzger著，王士帆譯（2014），國際刑法與歐洲刑法，臺北：元照。[Satzger, Helmut (2013), Internationales und Europäisches Strafrecht, 6. Aufl., München: C. H. Beck.]
- 王正嘉（2016），論死刑之裁量與界限：以兩公約與比較法為出發，臺大法學論叢，45卷2期，頁687-754。
- 朱石炎（2011），刑事訴訟法論，修訂3版，臺北：三民。
- 吳信華（2008），憲法訴訟——「訴訟類型」：第一講——「憲法訴訟」與「訴訟類型」的基本概念，月旦法學教室，66期，頁34-43。
- （2013），大法官規範審查程序中「擴張審理標的」之研究——以「重要關聯性」的探究為中心，東吳法律學報，24卷4期，頁1-63。
- 吳燦（2016），最高法院刑事案件之言詞辯論——兼論不得上訴第三審案件的救濟，法官協會雜誌，18卷，頁91-104。
- 李榮耕（2017），簡評釋字第752號解釋及刑事訴訟法的相關修正，月旦法學教室，181期，頁44-56。
- 林山田（2004），刑事程序法，5版，臺北：五南。
- 林永謀（2010），刑事訴訟法釋論（下冊），改訂版，臺北：自版。
- 林佳範（2010），論兩公約對憲法人權保障的補充——一個初步架構的探討，全國律師，14卷3期，頁23-41。
- 林超駿（2012），論合憲訴訟救濟制度之建構——從釋字第665號解釋出發，臺北大學法學論叢，82期，頁1-94。
- （2013），論合憲審級救濟之建構——以大法官立法裁量見解為中心，憲政時代，38卷3期，頁327-396。

- 林慈偉（2015），從公民與政治權利國際公約論死刑裁判之人權基準——最高法院近年相關裁判之綜合評析，軍法專刊，61卷4期，頁125-168。
- 林鈺雄（2013），2012年刑事程序法發展回顧：從國際人權公約內國法化的觀點出發，臺大法學論叢，42卷特刊，頁1067-1107。
- （2014），2013年刑事程序法發展回顧：從國際人權公約內國法化的觀點出發，臺大法學論叢，43卷特刊，頁1265-1298。
- （2015），2014年刑事程序法裁判回顧：從國際人權公約內國法化的觀點出發，臺大法學論叢，44卷特刊，頁1535-1566。
- （2016），2015年刑事程序法裁判回顧：從國際人權公約內國法化的觀點出發，臺大法學論叢，45卷特刊，頁1649-1678。
- （2017），刑事訴訟法（上冊），8版，臺北：自版。
- （2017），刑事訴訟法（下冊），8版，臺北：自版。
- 柯耀程（2017），限制三審上訴之規範檢討——評釋字第七五二號解釋，月旦法學雜誌，271期，頁147-154。
- 徐揮彥（2014），「公民與政治權利國際公約」與「經濟、社會與文化權利國際公約」在我國最高法院與最高行政法院適用之研究，臺大法學論叢，43卷特刊，頁839-909。
- 張文貞（2010），國際人權法與內國憲法的匯流：台灣施行兩大人權公約之後，收於：台灣法學會編，台灣法學新課題（八），頁1-26，臺北：元照。
- （2012），演進中的法：一般性意見作為國際人權公約的權威解釋，台灣人權學刊，1卷2期，頁25-43。
- （2015），國際人權公約與憲法解釋：匯流的模式、功能及台灣實踐，司法院大法官104年度學術研討會，司法院主辦，

2015年12月5日。

陳愛娥（2004），司法院大法官憲法解釋之標的——以聲請外解釋的認定困難為中心，台灣本土法學雜誌，59期，頁109-119。

陳運財（2001），我國刑事訴訟上訴審構造之檢討，收於：最高法院學術研究會編，「刑事訴訟起訴狀一本主義及配套制度」法條化研究報告（下），頁495-528，臺北：最高法院學術研究會。

彭坤業（2010），落實兩公約人權新紀元，全國律師，14卷3期，頁4-12。

黃明展（2010），論兩公約施行法之生效對判決與執行死刑之影響（上），司法周刊，1492期，頁2-3。

黃昭元（2015），公民與政治權利國際公約與憲法解釋，司法院大法官104年度學術研討會，司法院主辦，2015年12月5日。

黃舒芃（2015），國際及區域人權公約在憲法解釋中扮演的角色：兼評司法院釋憲實務對國際及區域人權公約之看待與引用方式，司法院大法官104年度學術研討會，司法院主辦，2015年12月5日。

廖宗聖（2011），公民與政治權利國際公約在我國的效力——以最高及高等法院刑事裁判為研究中心，中華國際法與超國界法評論，7卷1期，頁75-128。

廖福特（2010），法院應否及如何適用公民與政治權利國際公約，台灣法學雜誌，163期，頁45-65。

——（2013），聯合國與人權保障——監督機制、條約內涵、台灣實踐，臺北：新學林。

——（2014），「公民與政治權利國際公約」國內法化之影響：最高法院死刑相關判決之檢視，臺大法學論叢，43卷特刊，頁911-956。

——（2014），司法審判於兩公約人權保障思維所面臨之挑戰——行政法院適用兩公約之檢視，法學叢刊，59卷2期，頁1-42。

—— (2014)，最高法院的公民與政治權利國際公約難題／最高法院103台上3062判決，台灣法學雜誌，257期，頁193-196。

鄧衍森 (2010)，人權保障的規範理論：序曲，台灣法學雜誌，166期，頁123-130。

蘇凱平 (2017)，居於憲法訴訟權核心的冤罪防抑——評釋字第752號解釋，月旦裁判時報，66期，頁88-100。

2. 外文部分

Conte, Alex, and Richard Burchill. 2009. *Defining Civil and Political Rights: The Jurisprudence of the United Nations Human Rights Committee*. 2d ed. Abingdon: Routledge.

Human Rights Committee. 1985. Consuelo Salgar de Montejo v. Colombia. Communication No. 64/1979, U.N. Doc. CCPR/C/OP/1 at 127.

———. 1986. J. B. et al. v. Canada. Communication No. 118/1982, U.N. Doc. Supp. No. 40 (A/41/40) at 151.

———. 1991. Henry v. Jamaica. Communication No. 230/1987, U.N. Doc. CCPR/C/43/D/230/1987.

———. 1993. Douglas, Gentles and Kerr v. Jamaica. Communication No. 352/1989, U.N. Doc. CCPR/C/49/D/352/1989.

———. 1993. I. P. v. Finland. Communication No. 450/1991, U.N. Doc. CCPR/C/48/D/450/1991.

———. 1997. Kestutis Gelazauskas v. Lithuania. Communication No. 836/1998, U.N. Doc. CCPR/C/77/D/836/1998.

———. 2004. General Comment No. 31, Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13.

———. 2004. Jesús Terrón v. Spain. Communication No. 1073/2002, U.N. Doc. CCPR/C/82/D/1073/2002.

- . 2005. Gomariz Valera v. Spain. Communication No. 1095/2002, U.N. Doc. CCPR/C/84/D/1095/2002.
- . 2005. Leon R. Rouse v. Philippines. Communication No. 1089/2002, U.N. Doc. CCPR/C/84/D/1089/2002.
- . 2007. General Comment No. 32, Article 14: Right to equality before courts and tribunals and to a fair trial, U.N. Doc. CCPR/C/GC/32.
- Joseph, Sarah, and Melissa Castan. 2013. *The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials, and Commentary*. 3d ed. Oxford: Oxford University Press.
- Nowak, Manfred. 2005. *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*. 2d ed. Kehl: N.P. Engel.
- Trechsel, Stefan. 2005. *Human Rights in Criminal Proceedings*. Oxford: Oxford University Press.
- Tyagi, Yogesh. 2011. *The UN Human Rights Committee: Practice and Procedure*. Cambridge: Cambridge University Press.

Analyzing the Restrictions on Third-instance Appeals from the Perspectives of the ICCPR

*Tzu-Wei Lin**

Abstract

Although the restrictions on third-instance appeals contained in Article 376 of the Code of the Criminal Procedure were debated during the 1995 amendments, the issue deserves reexamination in light of Article 14(5) of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Now incorporated in domestic law, Article 14(5) protections has been given greater concrete interpretation by the Human Rights Committee. Yet, decisions by the Supreme Court have been unsatisfactory in protecting the right contained therein. Furthermore, J.Y. Interpretation No. 752 not only missed the opportunity to clarify the interplay between the ICCPR and constitutional interpretation, but also failed to address the constitutionality of Article 376 of the Code of Criminal Procedure. Therefore, judicial practice on third-instance appeals has gone from bad to worse. This article suggests that the legislature should revise restrictions on third-instance appeals comprehensively and, until such amendments are made, ordinary courts should mitigate controversies through interpretation.

KEYWORDS: ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), Act to Implement the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, Human Rights

* Legal Director, Taiwan Alliance to End the Death Penalty (TAEDP); Ph.D. Candidate, College of Law, National Chengchi University.

Committee, General Comments, right to appeal, right to review, fair trial, Judicial Yuan Interpretation No. 752, the right of instituting legal proceedings, Article 376 of the Code of Criminal Procedure.